Cristiano Chaves de Farias
Felipe Braga Netto
Nelson Rosenvald

Manual de Direito Civil

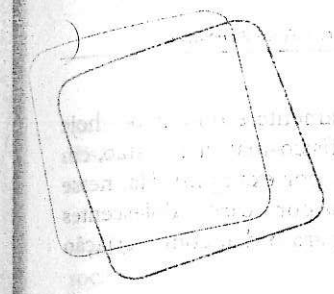
VOLUME ÚNICO

Professora Fabiana Dantas Soares
Alves da Mota
Matrícula Siape nº 1047726

4ª edição | revista atualizada ampliada

2019

EDITORA *jus*PODIVM
www.editorajuspodivm.com.br



1

DIREITOS DA PERSONALIDADE

1. DOS BENS MATERIAIS AOS BENS IMATERIAIS

"A cozinheira é Jandira. Mas esta é forte. Tão forte que é vidente. Uma de minhas irmãs estava visitando-me. Jandira entrou na sala, olhou sério para ela e subitamente disse: 'A viagem que a senhora pretende fazer vai se realizar, e a senhora está atravessando um período muito feliz na vida'. E saiu da sala. Minha irmã olhou para mim, espantada. Um pouco encabulada, fiz um gesto com as mãos que significava que eu nada podia fazer, ao mesmo tempo em que explicava: 'É que ela é vidente'. Minha irmã respondeu tranquila: 'Bom. Cada um tem a empregada que merece'".

Clarice Lispector

O elemento unificador do direito civil, por séculos, não foi a pessoa, e sim a propriedade. Ao se falar, atualmente, em repersonalização, este é o sentido das mudanças: colocar a pessoa humana no centro do sistema civil-material. Não se pretende, com isso, em absoluto, negar o caráter patrimonial de muitas das relações jurídicas que caracterizam o direito civil – seria ingênuo e até absurdo. Não devemos em postura maniqueísta – fácil de adotar no discurso, mas raramente vivenciada – demonizar os interesses patrimoniais. Os interesses patrimoniais não só recebem proteção constitucional como são, muitas vezes, o caminho para a realização de certos interesses existenciais. Todos nós desejamos, de certo modo, algum grau de independência financeira, até para que possamos "tomar as rédeas" da própria vida. É difícil ser livre quando não se tem dinheiro para o básico, para o aluguel, para cursar determinada faculdade privada, quando não se consegue vaga na pública. Nem falamos, aqui, das necessidades primárias como a alimentação. Rubem Braga, com a ironia de sempre, diagnosticou: "A melhor coisa de ter dinheiro é não ter que pensar, a todo momento, em dinheiro".

Aliás, se pensarmos bem – ainda sob um prisma puramente econômico – hoje os bens mais valorizados financeiramente não são apenas físico-materiais: estão, em grande parte, ligados a bens imateriais (mercado de ações, por exemplo). Há, nesse sentido, uma progressiva desmaterialização dos bens. Não por acaso, adolescentes e jovens tornam-se milionários (ou bilionários), da noite para o dia, com a criação de *aplicativos*.

Falando dos direitos da personalidade: sabemos, hoje, com toda clareza, que os bens mais valiosos, sob um prisma valorativo, não são aqueles patrimoniais, mas existenciais. Essa é talvez a mais paradigmática mudança no direito civil das últimas décadas. Não se trata de tornar menos importantes os bens patrimoniais, mas apenas de valorizar, de modo intenso e hermeneuticamente decisivo, os bens, valores e interesses ligados à tutela da pessoa humana. A teoria da personalidade, a teoria das incapacidades, a teoria do fato jurídico, tudo isso é atingido e ganha novas cores com uma concepção sistematicamente mais aberta do direito civil. Não só: propriedade, obrigações, famílias, sucessões, praticamente em todos os campos temáticos ocorreram significativos movimentos hermenêuticos, com claras consequências práticas resultantes da *repersonalização* e da *despatrimonialização* do direito civil. Enfim, como anteviu Pontes de Miranda, com a teoria dos direitos da personalidade alcançou-se "um dos cimos da dimensão jurídica"[1]. Trata-se, certamente, de categoria histórico-conceitual que opera sobretudo com o *ser*, e não com o *ter*. Por isso, talvez, tenha demorado tanto, historicamente falando, para surgir. É que, como dissemos, o elemento unificador do direito civil, por séculos, não foi a pessoa, e sim a propriedade.

2. A CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE: CONTRAPONDO A DIGNIDADE AO HORROR

> *"Entre a guerra e a paz eu escolhi a paz, assim eu decidi dentro do meu coração. Portinari, estou certo, sentiu o mesmo. Os cavalheiros que passam armados – minha amiga notou – não são guerreiros de verdade, são imagens que parecem estar mais no espírito das mulheres. É uma guerra subjetiva, em que se representa mais a tristeza que a violência. A guerra pintada por um pacifista".*
>
> Rubem Braga

Os direitos da personalidade são direitos indisponíveis, direitos formulados de modo cogente. Se alguém, por exemplo, concorda em ser mutilado e morto durante a gravação de certo filme, a pretexto da liberdade de expressão, isso não impedirá a responsabilização civil e penal dos agressores. Há, é verdade, atualmente, intensa discussão a respeito dos limites da autodeterminação, mas essa há de ser

[1] PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*. T., 7. Rio de Janeiro: Borsoi, p. 6.

compatibilizada sempre com a dignidade humana, à luz de cada contexto histórico. Historicamente, os direitos fundamentais foram formulados como formas de se exigir omissões dos poderes públicos[2].

Há direitos que, como categoria histórica, surgem como que em resposta a determinadas experiências – geralmente profundas e marcantes – vividas por determinada sociedade, ou mesmo pela espécie humana como um todo, naquilo que significa partilhar dores, lembranças e lições em comum. O nazismo foi uma dessas tenebrosas experiências – que, como quase todas as dores, encerram lições. Podemos, porém, sem dúvida, encontrar conexões históricas anteriores – como, por exemplo, com o Iluminismo.

A dignidade humana – como formulação jurídica – e a categoria conceitual dos direitos da personalidade surgiram como a resposta possível que a humanidade – e a própria Alemanha – resolveram dar ao problema[3]. Já vimos bem, com terríveis lentes brutais, aonde categorias neutras formais, duramente positivas podem nos levar. A isso contrapusemos valores e direitos e índole substantivo-material, representados fundamentalmente pelas cláusulas gerais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social. O livre desenvolvimento da personalidade há de contar, inegavelmente, com a proteção jurídica.

Seja como for, não se trata de algo dado, mas construído. Historicamente construído. Os direitos da personalidade, nesse contexto, são uma construção jurídica relativamente recente, fruto dos estudos da doutrina germânica e francesa, especialmente após a Segunda Guerra. A Alemanha, em especial, sentiu a necessidade de dar resposta ao mundo diante do terror que – sob a silenciosa complacência da ordem jurídica então vigente – se produziu. Não ficamos, porém, apenas na dimensão ética ou religiosa: demos um passo além. Hoje, fez-se jurídica a proteção, com normas imperativas e cogentes. Negar ou esvaziar os direitos da personalidade é atentar contra os pilares da ordem jurídica interna e supranacional. Não se trata, por certo, de assegurar esses direitos apenas formalmente (lembremos, por exemplo, que a primeira Constituição brasileira previa o princípio da igualdade – art. 178, XIII. Isso, porém, não impediu que sob sua vigência tivéssemos a mácula da escravidão)[4]. Bobbio, aliás, costumava ponderar que o problema mais grave do nosso tempo, em relação aos direitos fundamentais, não era mais o de justificá-los, mas sim o de protegê-los[5].

[2] BARILE, Paolo. *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*. Bologna: Il Molino, 1984.

[3] Conferir: HOFFMAN, Hasso. La promessa della dignità umana. La dignità dell'uomo nella cultura giuridica tedesca. *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*. Roma, pp. 620-650, out./dez 1999. Os códigos civis dos séculos passados, de modo geral, não faziam menção aos direitos da personalidade. Os códigos civis francês, alemão e italiano eram silentes. Com o pós-guerra, os códigos foram aos poucos reformados, passando a prever a nova categoria. Relevante contribuição foi produzida no direito alemão.

[4] O que não impediu que os melhores espíritos se colocassem contra esse estado de coisas. Teixeira de Freitas – talvez o maior jurista que tivemos, ao lado de Pontes de Miranda – recusou-se, ainda no século XIX, a inserir a escravidão no seu monumental projeto de Código Civil. Escreveu belamente: "Cumpre advertir que não há um só lugar do nosso texto, onde se trate de escravos. Temos, é verdade, a escravidão entre nós; mas, se esse mal é uma exceção que lamentamos, e que já está condenado a extinguir-se em uma época mais ou menos remota, façamos também uma exceção, um capítulo avulso, na reforma das nossas leis civis, não as maculemos com disposições vergonhosas, que não podem servir para a posteridade" (TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. *Consolidação das Leis Civis*. Rio de Janeiro: Typographia Universal de Laemmert., 1859, p. XI, ortografia por nós atualizada).

[5] BOBBIO, Norberto. *A Era dos Direitos*. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p. 25. Edward Telles diagnostica que uma sociedade democrática precisa de leis que possam, efetivamente, assegurar os direitos de todos os cidadãos, especialmente os mais desprotegidos. No Brasil, como no resto da América Latina, há uma

3. COMPREENDENDO O CONCEITO DE PESSOA: UM PASSO ALÉM DO FORMALISMO

Por muitos séculos, o direito civil apenas se ocupou do sujeito de direito, isto é, a pessoa como aquele ente que pode titularizar uma relação jurídica, no polo ativo ou passivo, como sujeito de direito e deveres (subjetivos). Esse conceito não deixou de existir, pelo contrário. Continua a existir e reflete uma realidade, normativa e conceitual, importante. Apenas não pode ser encarado sob um prisma puramente estrutural e formal.

Em sentido semelhante, argumenta-se que "a rigor, há dois sentidos técnicos para o conceito de personalidade. O primeiro associa-se à qualidade de ser sujeito de direito, conceito aplicável tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas. O segundo traduz o conjunto de características e atributos da pessoa humana, considerada objeto de proteção privilegiada por parte do ordenamento, bem jurídico representado pela afirmação da dignidade humana, sendo peculiar, portanto, à pessoa natural"[6]. Para concretizar, efetivamente – e não só no discurso – o princípio da dignidade, será fundamental que trabalhemos não só com a solidariedade social, mas também com a igualdade. Estrutural e funcionalmente é preciso repensar e desenvolver o princípio da igualdade substancial.

Passamos da estrutura à função[7]. E isso se reflete em vários institutos e conceitos. Entre eles o ser pessoa. Não mais olhamos o sujeito isolado, mas situado. Não só o texto, mas o contexto. Não só a estrutura, mas a função. Para bem compreender a função, é fundamental não analisar a pessoa apenas em sua dimensão isolada, mas situada, nas dimensões sociais, coletivas, de modo funcionalmente dinâmico. Como dissemos, a ideia de personalidade jurídica está ligada à ideia de sujeito de direito. Essa ligação continua importante, mas não é, hoje, suficiente. Conforme escrevemos em outra ocasião, "personalidade jurídica é, assim, muito mais do que, simplesmente, poder ser sujeito de direitos. Titularizar a personalidade jurídica significa, em concreto, ter uma tutela jurídica especial, consistente em reclamar direitos fundamentais, imprescindíveis ao exercício da vida digna. Em necessária perspectiva civil-constitucional, a personalidade não se esgota, destarte, na possibilidade de alguém (o titular) ser sujeito de direitos, mas, por igual, relaciona-se com o próprio ser humano, sendo a consequência mais relevante do princípio da dignidade do ser humano"[8].

persistente separação entre a democratização formal e a aplicação da lei (TELLES, Edward E. *O significado da raça na sociedade brasileira*. Trad. Ana Arruda Callado. Princenton e Oxford: Princenton University Press, 2012, p. 197).

6 BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de; TEPEDINO, Gustavo. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. V. I. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 4. Argumenta-se ainda que os direitos de personalidade consistem na proteção de atributos da personalidade humana. Cf. SZANIAWSKI, Elimar. *Direitos da personalidade e sua tutela*. São Paulo: RT, 2005, p. 20.

7 BOBBIO, Norberto. *Dalla Stuttura alla Funzione*. Milano: Edizione de Comunitá, 1977. Ver ainda: FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y garantías. La ley del más débil*. Trad. Perfecto András Ibáñez. Madrid: Trotta, 1999, pp. 73-96; PERLINGIERE, Pietro. *Perfis de Direito Civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 44; SEN, Amartya. *Desarrollo y Libertad*. Planeta: Barcelona, 2000.

8 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. *Curso de Direito Civil*. v. 1. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 17.

3.1. As múltiplas dimensões normativas da dignidade

A dignidade humana, como princípio normativo, projeta múltiplas dimensões horizontais e verticais, no direito público e privado, impondo não só abstenções (não violar a dignidade) mas também, cada vez mais, ações (no sentido de promovê-la). A dignidade é protetiva e promocional. É protetiva no sentido de garantir a todo ser humano um tratamento respeitável, não degradante, tutelando sua integridade psicofísica. É promocional no sentido de viabilizar condições de vida para que a pessoa adquira liberdade e possa projetar a direção que queira em sua existência.

Dworkin lembra que a dignidade possui "tanto uma voz ativa como uma voz passiva, que estão conectadas". A dignidade é simultaneamente limite e tarefa. Como limite (proteção), veda-se a *coisificação* do ser humano. Como tarefa (promoção) faz surgir deveres concretos de tutela por parte do Estado. Há direito fundamental às condições materiais que assegurem vida com dignidade. Um mínimo não apenas no sentido da sobrevivência física, mas sociocultural. Aliás, sabemos que só há real dignidade se houver padrões mínimos de liberdade e de igualdade material. O mínimo existencial é indissociável do conceitual atual de dignidade humana. Lembre-se ainda que os valores existenciais relativos à dignidade só são verdadeiramente resguardados se o forem preventivamente, e não só de modo repressivo e posteriormente imperfeito.

Dissemos acima que como tarefa (promoção) a dignidade faz surgir deveres concretos de tutela por parte do Estado. Essa dimensão positiva (eficácia ativa) da dignidade projeta efeitos normativos em outros direitos fundamentais sociais, como a segurança pública (que não tem sido, certamente, um dever levado a sério, entre nós).

Ainda a propósito da igualdade – e de suas conexões normativas com a dignidade – convém frisar que a igualdade, hoje, é encarada sob uma perspectiva concreta e não apenas abstrata. Nossa Constituição tem como objetivos fundamentais construir uma sociedade livre, justa e solidária (CF, art. 3º, I), garantir o desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, II), erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (CF, art. 3º, III), promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (CF, art. 3º, IV). A descrição da norma constitucional permite perceber que a igualdade aí consagrada é substancial (e não formal). Convém lembrar que a igualdade substancial, no Brasil, não é um dado de realidade, é um objetivo a ser buscado e construído. E a igualdade não se restringe à proibição de exclusão. Igualdade é também obrigação de inclusão.

4. AS DEMOCRACIAS CONSTITUCIONAIS CONTEMPORÂNEAS E AS ESFERAS AUTODETERMINATIVAS

Já mencionamos o ponto anteriormente (em mais de uma oportunidade, neste livro). Hoje cada vez mais a *liberdade de escolhas existenciais fundamentais* surge como um bem jurídico de extraordinária valia. Nas sociedades democráticas, prevalece – ou

deve sempre prevalecer – o direito de escolha acerca do próprio destino. Ou seja, cada ser humano é livre para escrever, com as tintas que preferir, seus caminhos, suas trajetórias, suas buscas[9].

O livre desenvolvimento da personalidade está, em boa medida, relacionado à autodeterminação. Ser livre – ou pelo menos um dos aspectos da plurissignificativa expressão – é poder definir o livro da própria vida, escolher o rumo das escolhas íntimas fundamentais, naquilo que perfaz o presente e, em grande parte, o futuro. Somos, em grande parte, fruto de nossas escolhas. Aliás, um escritor francês disse que achamos difícil ser felizes porque enxergamos o passado melhor do que ele foi, o presente pior do que é, e o futuro menos resolvido do que será.

O direito civil de hoje cada vez mais reconhece no ser humano uma fonte de escolhas íntimas que deverão ser respeitadas. Com autonomia moral, racional e existencial. Nossos projetos de vida, nossas situações existenciais, são espaços juridicamente resguardados. As democracias constitucionais contemporâneas reconhecem – e valorizam – uma ampla esfera autodeterminativa para o ser humano[10].

Enfim, a herança cultural que o direito atual deixará às futuras gerações, além de um crescente diálogo ético, será o respeito ao pluralismo.

5. DISTINGUINDO DIREITOS DA PERSONALIDADE, DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS HUMANOS

As três expressões – direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade – refletem realidades convergentes. Quando as diferentes expressões dizem respeito a fenômenos idênticos, a diferença é apenas terminológica. Porém, mesmo a diferença terminológica está ligada, sobretudo, a uma diferença de abordagem (historicamente, os direitos humanos e os direitos fundamentais foram construídos, pelo menos na fase inicial, como direitos oponíveis ao Estado). As expressões, portanto, muitas vezes, dizem respeito a fenômenos idênticos, embora nem sempre. Há, porém, distinções que vão além da terminologia.

Direitos humanos é uma expressão que tende a constar em tratados internacionais, sendo também muito invocada em outros ramos do direito, de uso mais raro, porém, no direito civil.

Abrangem não só os direitos da pessoa humana em si mesma (vida, honra, intimidade), mas também os direitos sociais – direito ao trabalho, por exemplo –, e também os direitos políticos – como o direito de participar ativamente da vida política do Estado, por exemplo. Não é difícil perceber, nesse contexto, que os direitos humanos gozam de espectro temático mais amplo que os direitos da personalidade. Os direitos humanos, em perspectiva histórica, exigiam inicialmente abstenções estatais,

[9] Conferir: FRIEDMAN, L. M. *The Republic of Choice: Law, Authority and Culture*. Cambridge: Harvard UP, 1990.

[10] Conferir, a propósito: RODOTÀ, Stefano. *La vida y las reglas. Entre el derecho y el no derecho*. Traducción de Andrea Greppi. Madrid: Editorial Trotta, 2010, especialmente o ensaio *El derecho y su límite*, p. 25-71. Conferir ainda: AMARAL, Francisco. A autonomia privada como princípio fundamental da ordem jurídica: perspectiva estrutural e funcional. *Revista de Direito Civil*. São Paulo, n. 46, pp. 07-26, out.-dez. 1988.

eram direitos dirigidos apenas ao Estado[11]. O caminhar histórico revelou que eles são dirigidos não só contra o Estado, mas também contra os demais particulares. Ademais, a postura estatal não deve ser apenas de abstenção (não os violar), mas hoje, cada vez mais, de ação (promovê-los e evitar que os demais particulares os violem).

Os direitos fundamentais são direitos humanos que lograram inserção nos textos constitucionais. São direitos consagrados, portanto, nas constituições. Há um passo além, em relação a eles, na direção da normatividade. Lembremos que nossa Constituição, no Título II, consagra os direitos e garantias fundamentais. Estamos diante, aí, de direitos fundamentais. O direito ao *habeas corpus*, por exemplo, é um direito fundamental (Constituição Federal, art. 5º, LXVIII). Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Os direitos humanos, nesse sentido, são consagrados em tratados internacionais, ao passo que os direitos fundamentais são consagrados nas constituições dos países, podendo variar de um para outro (lembremos, por exemplo, que o direito de portar armas é um direito fundamental nos Estados Unidos, garantido pela Segunda Emenda).

Já os direitos da personalidade são os direitos fundamentais, estudados e desenvolvidos pela doutrina do direito privado, a partir de Otto Von Gierke. Não só, por certo, na doutrina, mas também e sobretudo nas normas jurídicas civis. Possuem forte ligação com a proteção da dignidade humana, em suas múltiplas dimensões, materiais e imateriais. Francisco Amaral pondera que todos os direitos da personalidade são direitos fundamentais, mas não o inverso[12] (há, por exemplo, direitos políticos que são direitos fundamentais, mas não são direitos da personalidade).

Em geral, esses direitos acima mencionados eram direitos protegidos apenas no âmbito do direito público (no direito constitucional e, antes, no direito penal). Punia-se o homicídio, punia-se a lesão corporal, punia-se a calúnia etc. Limongi França percebeu que até a definição dos direitos da personalidade pelos juristas alemães, "só lhes reconhecia a tutela pública, através dos direitos constitucional e penal"[13]. A partir do final do século XIX, no entanto, o direito civil percebeu que essas violações infringiam, também, normas de direito civil.

[11] Vale citação clássica do Ministro Celso de Mello: "Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade (STF, Pleno, MS 22.164, Rel. Min. Celso de Mello). Consultar, sobre o tema, COMPARATO, Fábio Konder. *A afirmação histórica dos direitos humanos*. São Paulo: Saraiva, 1999.

[12] Assim, "cabe destacar que os direitos da personalidade surgiram nos textos fundamentais como *direitos naturais* ou *direitos inatos*, que se denominam inicialmente *direitos humanos* assim compreendidos os direitos inerentes ao homem. Alguns desses direitos humanos são positivados nos textos constitucionais, passando a chamar-se *direitos fundamentais*, como objetivo de especial garantia em face do Estado. Os direitos fundamentais seriam um núcleo ou círculo mais restrito de direitos humanos especialmente protegidos pela Constituição" (AMARAL, Francisco. *Direito Civil. Introdução*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 257). Paulo Lôbo argumenta que "nem todos os direitos fundamentais, corporificados ou não na Constituição, são direitos da personalidade" (LÔBO, Paulo. *Direito Civil. Parte Geral*. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 137).

[13] FRANÇA, Rubens Limongi. *Manual de Direito Civil*. v. 1. São Paulo: RT, 1971, p. 322. Francisco Amaral afirma, de modo luminoso, que "por terem guarida no texto constitucional, pode reconhecer-se que os direitos da personalidade

5.1. Discriminação de fato e discriminação indireta (teoria do impacto desproporcional)

"Não me peça que lhe faça uma canção como se deve
Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve".

Belchior

Daniel Sarmento menciona as duas teorias em valioso estudo acerca da igualdade étnico-racial no direito constitucional brasileiro[14]. Lembremos que a igualdade, hoje, é encarada sob uma perspectiva concreta e não apenas abstrata. E que – ao contrário do que às vezes se afirma – nossa Constituição contempla a igualdade não apenas formal, mas substancial, como fica claro a partir da leitura do art. 3º. Também já mencionamos que a igualdade substancial, sobretudo no Brasil, não é um dado de realidade, é um objetivo a ser buscado e construído.

A "discriminação de fato", porém, não é uma hipótese de igualdade *na* lei, mas sim *perante* a lei. Não se trata de postular a invalidade do ato normativo por violação da isonomia. Mas apenas constatar que a lei, embora válida, tem sido, na prática, aplicada de modo sistematicamente prejudicial a determinado grupo (aí, portanto, reside a discriminação). Se, por exemplo, conforme menciona o autor, for estatisticamente comprovado que a polícia realiza revistas pessoais em negros com frequência muito superior àquela praticada em outros cidadãos. Há, aí, sem dúvida, violação ao princípio da igualdade.

Já na "discriminação indireta" (*teoria do impacto desproporcional*) há uma medida, pública ou privada, que embora pareça neutra, na verdade não é. A diferença entre a "discriminação de fato", abordada no parágrafo anterior, e a "discriminação indireta" (*teoria do impacto desproporcional*), é que esta não comporta aplicação harmônica com o princípio da igualdade (no exemplo anterior, a norma que permite que a polícia realize revistas pessoais nos carros pode ser aplicada de modo compatível com a igualdade). Um exemplo possível – julgado pelo STF, embora sob diversa fundamentação – é o seguinte: determinada norma previa que a Previdência Social só responderia por determinado valor (mínimo) da licença da gestante. O resto ficaria sob responsabilidade do empregador. Essa medida, embora aparentemente neutra, na prática teria um claro efeito perverso: os empregadores evitariam, por certo, contratar mulheres, sobretudo se em idade fértil[15].

são o *terreno de encontro privilegiado entre o direito privado, as liberdades públicas e o direito constitucional*".

14. SARMENTO, Daniel. *Livres e iguais: estudos de direito constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, especialmente páginas 147-153.

15. Um outro exemplo citado pelo autor: "A Corte Europeia de Justiça também tem usado a teoria do impacto desproporcional para coibir as discriminações indiretas no campo da igualdade de gênero. O primeiro precedente ocorreu no julgamento do caso 170/84, *Bilka-Kaufhaus vs. Von Hartz*, em que se discutia a validade de um sistema privado de pensão mantido por empresa germânica, o qual negava o benefício a empregados que trabalhassem em regime de tempo parcial, à luz do art. 119 do Tratado de Roma, que garante a igualdade entre mulheres e homens em relação ao trabalho. Embora não houvesse ali explícita discriminação de gênero, a Corte entendeu que seria inválido o sistema, porque afetaria de forma muito mais intensa as mulheres do que os homens, já que são elas as que, na grande maioria dos casos, trabalham em regime parcial" (obra citada, p. 150). Também no Brasil, de modo progressivo, os tribunais parecem cada vez mais sensíveis aos impactos reais de determinadas medidas em relação à igualdade substancial.

6. QUAL A TERMINOLOGIA MAIS ADEQUADA? ENTENDENDO AS INTEGRIDADES FÍSICA, MORAL E INTELECTUAL

"Todo mundo tem vários problemas emocionais, grandes e pequenos. A maioria não é consciente, mas sempre condiciona nosso comportamento".

Joseph Ross

Não há, em relação aos direitos da personalidade, um consenso quanto à terminologia mais adequada para exprimir o fenômeno dos direitos que se apresentam como essenciais à dignidade e integridade humanas (sabemos, aliás, que os consensos são cada vez mais raros na experiência jurídica contemporânea). Pode-se, porém, apontar que a expressão "direitos da personalidade" é largamente usada entre nós, particularmente no direito civil (e foi, ademais, consagrada no Código Civil, no capítulo que vai do art. 11 ao art. 21).

Como resume Carlos Alberto Bittar, alguns autores inclinam-se por denominar *direitos essenciais da pessoa* (Ravà), *direitos pessoais* (Bruns) e *direitos personalíssimos* (Pugliati, Chiovenda e Rotondi). No entanto, a expressão dotada de maior técnica e consagrada na doutrina brasileira (Orlando Gomes, Limongi França e Antônio Chaves) e estrangeira (De Cupis e Gierke) tem sido, realmente, "*direitos da personalidade*". Cabe mencionar que a paternidade da expressão "direitos da personalidade" é atribuída a Otto Gierke.

Seja como for, podemos caracterizar os direitos da personalidade como direitos subjetivos cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim seus prolongamentos e projeções (por isso, Donellus os tinha como *iura in persona ipsa*)[16]. Os direitos de personalidade, na formulação tradicional, surgem no instante do nascimento com vida e cessam com a morte. Hoje, porém, cada vez mais – conforme veremos –, discute-se os reflexos dos direitos da personalidade *antes* do nascimento (a questão não só do nascituro, mas também dos embriões) e também *depois* da morte (a questão, por exemplo, entre outras, da imagem da pessoa falecida).

Hoje é muito conhecida a distinção que se faz – a respeito dos direitos da personalidade – em direitos à integridade física, moral e intelectual (com várias espécies). A distinção remonta a Limongi França. Hoje, porém, não se deve continuar a tratar a matéria da mesma forma que era tratada há algumas décadas. É preciso inserir, nas classificações, os novos direitos que a doutrina e a jurisprudência mais atentas vêm revelando. Assim, a integridade física (abrangendo, por exemplo, dentre outros, o direito à vida, ao corpo, a partes separadas do corpo, ao corpo mesmo sem vida, o direito à verdade sobre a própria origem genética etc.), a integridade intelectual (compreendendo, por exemplo, dentre outros, a liberdade de pensamento e de expressão, a liberdade religiosa, o direito autoral – qualquer que seja a espécie

16. FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da Personalidade. *Revista dos Tribunais*, n. 567, p. 9, jan. 1983.

da criação artística ou científica) e o direito à integridade moral ou psíquica (compreendendo, por exemplo, dentre outros, direito à imagem, à honra, à privacidade etc. Além do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, o direito à autodeterminação informativa, o direito à identidade sexual etc.). São muitas e variadas as dimensões contemporâneas dos direitos da personalidade. Elas se interpenetram e não há, a rigor, separação rígida ou estanque entre elas.

Vejamos, brevemente, cada uma das clássicas formas dos direitos da personalidade.

6.1. Direito à integridade física

A tutela da integridade física, em relação aos direitos da personalidade, é tratada fundamentalmente sob três aspectos: a) tutela do corpo vivo; b) tutela do corpo morto; c) autodeterminação do paciente.

O direito à integridade física diz respeito à proteção jurídica do corpo humano, isto é, sua incolumidade corporal, incluída a tutela do corpo vivo e do corpo morto, além dos tecidos, órgãos e partes suscetíveis de separação e individuação.

Em relação à tutela do corpo vivo, o Código Civil, art. 13, dispõe que "salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrair os bons costumes". Comecemos pela palavra final: já tivemos oportunidade de criticar, nesta obra, a expressão "bons costumes". O direito civil atual deveria evitá-la. É uma expressão de uma época que passou, não dos nossos dias. Ela exalta uma moral pesada e rígida (não uma ética aberta e tolerante). Há cerca de dez anos escrevemos que "bons costumes é uma expressão cujo conteúdo nos remete a uma moral oficial, linear e preconceituosa. Andaria melhor o Código de 2002 se não a trouxesse"[17]. Um juiz de outros tempos poderia invocar o dispositivo e proibir tatuagens, por exemplo. O mesmo se diga das cirurgias de troca de sexo (que são feitas, hoje, pelo SUS). A expressão, portanto, precisa estar de acordo com as legítimas expectativas sociais dos nossos dias.

Em relação à tutela do corpo morto, o Código Civil, art. 14, disse ser "válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte". Trata-se de ato necessariamente gratuito e revogável a qualquer tempo. Há de se entender que a vontade manifestada pelo doador de órgãos, por exemplo, prevalece sobre a vontade dos familiares. A doação de órgãos duplos ou regeneráveis pode ocorrer ainda em vida.

6.1.1. A questão da exigência médica e a autodeterminação corporal

Frisamos acima que o Código Civil, no art. 13, prevê que "salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrair os bons costumes". O artigo, se interpretado de forma literal, se chocaria com muitas práticas sociais hoje amplamente aceitas. Vejamos uma delas: cirurgia plástica com fins estéticos.

[17] BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. *Responsabilidade Civil*. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 101.

Dissemos que a disciplina do Código Civil para os direitos da personalidade não foi feliz. De fato. Os exemplos são muitos. Não faz sentido interpretar o art. 13 do Código Civil como se apenas por exigência médica fosse possível o ato de disposição do próprio corpo. Se fosse assim, praticamente nenhuma cirurgia plástica com fins estéticos seria possível, o que seria absurdo (o Brasil, em 2016, superou os EUA, e hoje lidera o ranking de cirurgias plásticas com fins estéticos no mundo).

A prática, além de obviamente lícita, é amplamente aceita, é algo que se incorporou fortemente aos costumes sociais do século XXI. Fábio Ulhoa Coelho lembra o preconceito que cercou, no início, a cirurgia plástica de objetivos meramente estéticos: "A doutrina noticia célebre julgado da primeira metade do século passado, em França, em que o cirurgião plástico foi condenado, por erro médico, a indenizar a paciente. O interesse no caso não reside tanto na decisão condenatória – afinal, os relatos indicam ter mesmo ocorrido uma deplorável imperícia do profissional. O interesse está, como aponta Aguiar Dias, na condenação do próprio procedimento: considerou-se que a responsabilidade do médico decorria de ter concordado em fazer operação plástica em pessoa completamente sã, apenas com o objetivo de aprimoramento estético. A jovem paciente era bonita e esbelta, mas tinha as pernas desproporcionalmente grandes. O objetivo da intervenção foi reduzi-las por ablação de gordura (o que foi motivo de verdadeiro escândalo naquela época é hoje largamente aceito e praticado em inúmeras clínicas de lipoaspiração de todo o mundo). Em outros termos, assentou-se que, se o único objetivo da operação cirúrgica é aformoseamento estético de pessoa saudável, realizá-la já é, por si, conduta culposa"[18].

Há, obviamente, exageros e equívocos. Mas é algo que deverá ser resolvido com o psiquiatra, não com o Código Civil.

6.1.2. A questão do consentimento informado

No que toca à autodeterminação do paciente, o Código Civil, art. 15, prevê que "ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica". Trata-se de disposição até certo ponto óbvia, de escassa utilidade. O tema ganha mais interesse se o conectamos com a questão do *consentimento informado*. Um médico, por exemplo, não deve, sem autorização do paciente, durante a realização de cirurgia ou procedimento ambulatorial, tomar decisões que poderiam ser tomadas, posteriormente, pelo paciente, sem que a demora represente risco. Sobretudo, por certo, quando tais decisões ostentam o caráter da irreversibilidade (amputações, retiradas de tecidos etc). Trata-se, obviamente, de orientação genérica que comportará exceções, à luz dos casos concretos: se a intervenção é de urgência, e a amputação, digamos, ou é feita naquele momento ou pode comprometer a vida do paciente (gangrena, por exemplo), estaremos diante da exceção legítima e autorizada. O julgador, ademais – e isso nem sempre é lembrado –, precisa ter presente que muitas vezes é a audácia (segura) do médico que pode salvar a vida do paciente. Um médico inseguro ou cauteloso demais nada faria. E a omissão excessivamente cautelosa pode ser trágica para o paciente.

[18] COELHO, Fábio Ulhoa. *Direito Civil, v. 2*. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 323.

Estamos diante da saúde humana, em sua indissociável integralidade. Não se admite, aqui, consentimentos para a prática de danos, quaisquer que sejam. Afirmar isso não equivale a negar qualquer validade para o chamado consentimento informado. O consentimento informado – cujo ônus da prova caberá sempre ao médico ou a instituição de saúde – *poderá*, conforme o caso, ostentar prestabilidade jurídica, desde que o procedimento ou tratamento seja adequado e proporcional, diante da situação fática posta. Não, porém, como mero formulário padrão, mas como dever de informar – bem, leal e concretamente – acerca dos riscos e possibilidades do tratamento. Nesse contexto, o formulário poderá, também, ser usado, mas não imuniza, de modo absoluto, a responsabilidade civil dos médicos ou planos de saúde diante da informação falha, defeituosa ou omissa[19]. Aliás, a autodeterminação, no direito dos nossos dias, assume relevância em variadas matérias. Por exemplo, a autodeterminação do paciente só pode ser verdadeiramente exercida se as informações prestadas forem específicas para o caso do paciente, e não genéricas. O consentimento também não pode ser genérico. Dessa forma, "haverá efetivo cumprimento do dever de informação quando os esclarecimentos se relacionarem especificamente ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica. Da mesma forma, para validar a informação prestada, não pode o consentimento do paciente ser genérico (*blanket consent*), necessitando ser claramente individualizado" (STJ, REsp 1.540.580). O STJ, em 2018, nos termos descritos, entendeu que a inobservância do dever de informar e de obter o consentimento informado do paciente viola o direito à autodeterminação e caracteriza responsabilidade extracontratual. Nesse sentido, inclusive, convém reconhecer que a pessoa humana é titular do seu prontuário médico, a ela pertencendo, e não ao médico. Bem por isso, a Lei nº 13.787/18 dispôs sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, manuseio e armazenamento de prontuários médicos, sempre zelando pela confidencialidade das informações nele contidas.

6.1.3. A questão dos transplantes: entre vivos e após a morte do doador

O corpo humano, vivo ou morto, integra a personalidade civil, e se caracteriza como coisa fora do comércio (*extra commercium*). O mesmo vale para partes do corpo humano. Admite-se, no entanto, atos de disposição de partes do corpo humano, vivo ou morto, a título gratuito, se não causar prejuízo ao titular e se tiver finalidades terapêuticas, altruísticas ou científicas (Código Civil, arts. 13 e 14). Convém, nesse contexto, diferenciar o transplante de órgãos humanos entre pessoas vivas e o transplante *post mortem*. A pessoa maior e capaz pode dispor, em vida, de tecidos, órgãos e partes do corpo para finalidades terapêuticas e para transplantes. Fundamental: o ato precisa

[19] Feitas essas ponderações, repita-se que não se admitem, aqui, consentimentos para que danos sejam praticados contra o corpo humano. Pontes de Miranda já houvera observado que "o consentimento não afasta a responsabilidade do médico por seus erros, ou descuidos, tanto mais quando o cliente ou a pessoa atendida em caso de acidente pode somente ter consentido porque o médico lhe expôs erradamente ou de má-fé (*e.g.*, para ganhar o dinheiro da operação), o que seria a sua doença" (PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*, t. 53. Rio de Janeiro: Borsoi, 1972, p. 436). Aliás, nas relações de consumo – e a relação entre médico e paciente é relação de consumo, salvo se o atendimento se dá em hospital público ou posto de saúde – são nulas as cláusulas que afastem ou mesmo atenuem o dever de indenizar (CDC, art. 51, I). A propósito do tema, convém lembrar que o Código de Ética Médica prevê, no art. 22, ser vedado ao médico "deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte".

ser gratuito. Outro ponto de total relevância: o ato somente é possível se não causar risco de morte ou de danos graves ao titular. Nesse contexto, como dissemos antes, somente partes renováveis do corpo ou órgãos duplos podem ser objetos de doação em vida. No caso de transplante entre pessoas vivas permite-se ao doador escolher o beneficiário do transplante (isto é, quem vai receber o órgão). Em princípio, deverá ser alguém da família. Em casos excepcionais, razoáveis e justificados, poderá ser outra pessoa. De qualquer modo, o comércio de órgãos humanos é obviamente vedado.

Bem diferente é a disciplina dos transplantes após a morte do doador. Nesse caso, veda-se a escolha do beneficiário. Existe uma fila de espera, de caráter nacional, com o propósito de uniformizar o procedimento e garantir a igualdade de chances. Existem, nos diferentes estados da federação, as centrais de notificação (que captam e distribuem os órgãos). A manifestação de vontade – sobre ser ou não doador de órgãos – que alguém faz em vida é que deverá prevalecer. Se não houver essa manifestação, vale a vontade da família[20].

6.1.4. A questão da recusa de consciência x transfusão de sangue

São bastante conhecidas as (difíceis) polêmicas envolvendo a recusa de sangue em procedimentos médicos, quase sempre relacionadas a questões religiosas, sobretudo daqueles que professam a religião conhecida como Testemunhas de Jeová. Já manifestamos, em outra oportunidade, nossa posição quanto à prevalência – em nosso sentir – da validade da recusa de consciência, desde que não se trate de menor de idade, ou alguém diante de situação de emergência[21]. Seja como for, a questão exige, fundamentalmente, ponderação à luz das especificidades do caso concreto, não aceitando solução apriorística.

Feitas essas colocações, devemos destacar que a questão hoje está assim visualizada pela maioria da doutrina e pelos tribunais: se o paciente for menor, ou, se maior, estiver diante de uma emergência médica (iminente perigo de morte), a transfusão deverá se impor, independentemente do consentimento ou autorização de familiares. No caso do paciente menor, o STJ, sob o prisma penal, entendeu que a conduta dos pais que recusam o tratamento para o filho é atípica, porém os médicos devem desconsiderar

[20] Em outubro de 2017 foi editado o Decreto n. 9.175, que regulamenta a Lei n. 9.434/97. Dispõe que o transplante, o enxerto ou a retirada de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano somente poderão ser realizados em estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, por equipes especializadas autorizadas pelo Sistema Nacional de Transplantes. O art. 17 dispõe que a retirada de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano poderá ser efetuada após a morte encefálica, com o consentimento expresso da família. E o art. 20 trata do consentimento familiar, prescrevendo que "a retirada de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano, após a morte, somente poderá ser realizada com o consentimento livre e esclarecido da família do falecido, consignado de forma expressa em termo específico de autorização". Nossa legislação adota, na matéria, o princípio do consenso afirmativo, devendo prevalecer a vontade do doador (ou de seus familiares) em sentido afirmativo. Na prática, porém, tem sido a vontade da família que prevalece.

[21] FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. *Curso de Direito Civil. Parte Geral e LINDB*. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 241-242. Cabe – a propósito dos direitos da personalidade – frisar que a proteção da integridade física compreende também a vedação da internação forçada (seja em clínicas psiquiátricas, seja em casas religiosas etc.). Convém ler o que dissemos, de modo mais amplo, no capítulo *A nova teoria das capacidades*. A propósito do tema, o STJ decidiu: "É incabível a internação forçada de pessoa maior e capaz sem que haja justificativa proporcional e razoável. A internação compulsória de filha maior e capaz em clínica para tratamento psiquiátrico, sem que haja efetivamente diagnóstico nesse sentido, configura constrangimento ilegal" (STJ, HC 35.301, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 13/09/2004).

a opinião dos pais e realizar o devido atendimento (STJ, HC 268.459, DJ 28/10/2014). O tribunal consignou que "no juízo de ponderação, o peso dos bens jurídicos, de um lado, a vida e o superior interesse do adolescente, que ainda não teria discernimento suficiente (ao menos em termos legais) para deliberar sobre os rumos de seu tratamento médico, sobrepairam sobre, de outro lado, a convicção religiosa dos pais, que teriam se manifestado contrariamente à transfusão de sangue. Nesse panorama, tem-se como inócua a negativa de concordância para a providência terapêutica".

Já se a pessoa é maior e capaz, e o caso não configura nenhuma emergência médica, o direito à vida se opõe de modo (ainda mais) problemático à liberdade religiosa, perfazendo autêntico *hard case*. Não há soluções fáceis ou simples. Embora a jurisprudência tenda a manifestar preferência pela proteção à vida, na doutrina parece prevalecer a autonomia do paciente. O Enunciado 403 das *Jornadas de Direito Civil* destaca: "O direito à inviolabilidade de consciência e de crença, previsto no art. 5º, VI, da Constituição Federal, aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta dele, desde que observados os seguintes critérios: a) capacidade civil plena, excluído o suprimento pelo representante ou assistente; b) manifestação de vontade livre, consciente e informada; e c) oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do declarante".

6.1.5. A questão dos danos à pessoa morta e os lesados indiretos

O Código Civil, no art. 12, parágrafo único, confere tutela jurídica não apenas às pessoas que foram *lesadas diretamente* (referidas no *caput*), mas, por igual, às pessoas que foram *lesadas indiretamente*, indicadas no seu parágrafo único: o cônjuge sobrevivente (e, por evidente, o companheiro também), os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o quarto grau.

É que quando uma ofensa (lesão à imagem, por exemplo) é dirigida diretamente a uma pessoa já falecida, não produz qualquer efeito jurídico, na medida em que o morto não mais ostenta personalidade jurídica. No entanto, o dano termina por atingir, embora indiretamente, os familiares vivos. Em relação ao falecido, não há repercussão jurídica, mas é possível violar direitos dos vivos, por vias transversas. Trata-se de dano por ricochete, reflexo. Isso porque atinge os familiares do falecido (cônjuge ou companheiro, hétero ou homoafetivo, ascendentes, descendentes ou colaterais até o quarto grau). Defendemos uma compreensão exemplificativa, não taxativa, do rol de legitimados, não se podendo negar a enteados, padrastos, amigos, noivos ou namorados o dano indireto decorrente da agressão ao morto.

Trata-se, assim, de exercício de um direito próprio (de uma legitimidade autônoma para ajuizar uma ação) e não mera substituição processual. Bem por isso, os lesados indiretos atuam *em nome próprio, defendendo um interesse próprio*, consistente na defesa da personalidade de seus parentes (ou de seu cônjuge ou companheiro) falecidos[22]. Agem, pois, por *legitimidade ordinária, autônoma*, e não em substituição

[22] Ademais, convém pontuar a inaplicabilidade, na hipótese, da ordem de vocação hereditária do direito das sucessões, não havendo grau sucessivo para a legitimidade em exame. Assim, a legitimidade dos *lesados indiretos* é autônoma, possuindo cada um deles (cônjuge, companheiro ou parceiro homoafetivo sobrevivente, filhos, netos, pais, irmãos, tios...) legitimidade para reclamar o dano sofrido, em nome próprio e pleiteando uma indenização própria. Convém não confundir a legitimidade dos lesados indiretos com a situação mencionada no art. 943 do Código Civil, que trata da *transmissão do direito à reparação do dano causado a alguém que morreu, após sofrer a afronta*. A diferença é elementar: os lesados indiretos pleiteiam em nome próprio um dano causado aos seus parentes mortos, *depois do óbito deles*; a outro giro, se o ofendido morreu sem promover a ação reparatória, os seus parentes vivos podem fazê-lo, dentro do prazo prescricional. Note-se que, nesse segundo caso, os parentes receberam, por transmissão hereditária, o direito à reparação do dano, podendo pleitear o que caberia ao falecido, em nome dele. Na primeira hipótese, os parentes são as próprias vítimas, reclamando em seus próprios nomes.

processual. É intuitivo, inclusive, que os lesados indiretos possuem legitimidade para requerer a reparação não somente na hipótese de morte real (natural) do seu cônjuge, companheiro ou parente, mas, também, na hipótese de morte presumida (declaração de ausência).

6.1.6. A questão da mudança de sexo e mudança no registro

As cirurgias de mudança de sexo são um assunto que se incorporou aos debates dos nossos dias. São também conhecidas como *transgenitalização* ou de *redesignação sexual*. O Conselho Federal de Medicina disciplina o tema através da Resolução n. 1.955/2010, fixando rígidos critérios para que o procedimento possa ocorrer. A cirurgia, prevê a citada resolução, não depende de autorização judicial, e pode ser realizada em hospitais públicos ou privados (se a mudança for de adequação do fenótipo feminino para o masculino, só poderá ser feita em hospitais públicos ou universitários). As *Jornadas de Direito Civil* decidiram que "o art. 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do próprio corpo por exigência médica, autoriza as cirurgias de transgenitalização, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina e a consequente alteração do prenome e do sexo no Registro Civil" (Enunciado n. 276). Antes, já apontara que "a expressão 'exigência médica' contida no art. 13 do Código Civil refere-se tanto ao bem-estar físico quanto ao bem-estar psíquico do agente" (Enunciado n. 6).

O outro aspecto juridicamente relevante da questão é o seguinte: uma vez realizada a cirurgia, é possível a modificação do nome no registro civil? Houve, nas últimas décadas, polêmicas e debates sobre a questão, com forte resistência inicial. Inicialmente não se aceitava, depois se aceitava parcialmente (desde que constasse no registro o motivo da mudança), num momento posterior se aceitou a mudança do nome sem menção ao motivo da mudança. Atualmente, foi-se além: admite-se a mudança não só do nome, mas do próprio gênero no registro civil. Ou seja, admite-se a mudança formal, cartorária, do sexo: mudança de homem para mulher, por exemplo. Mas essa mudança só era possível para quem tivesse realizado a cirurgia de redesignação sexual (STJ, REsp 1.008.398). Agora não mais: atualmente aceita-se a retificação do registro de nascimento para troca de prenome e do sexo (com mudança de gênero: masculino para feminino, por exemplo), sem que para isso seja necessária a realização de cirurgia de transgenitalização (STJ, REsp 1.626.739).

Lembremos, em relação à honra, que encerra dois diferentes aspectos: a honra objetiva e a honra subjetiva. A honra objetiva diz respeito à reputação que terceiros dedicam a alguém (a coletividade). Já a honra subjetiva diz respeito ao próprio juízo valorativo que cada um tem de si. Relaciona-se com a autoestima. Ambas as espécies de honra – objetiva e subjetiva – podem ser feridas por ato de outrem, ambas as violações, portanto, perfazem dano indenizável.

6.2.1. Direito à imagem

Cabe analisar uma das mais importantes projeções da integridade moral, que é o direito à imagem (tão complexo na sociedade atual). Conforme veremos adiante, o direito à imagem pode ser violado com ou sem violação à honra. Mas há certos aspectos que devem ser tratados aqui, desde logo. A Constituição Federal diz serem invioláveis "a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" (art. 5º, X). O mesmo artigo, no inciso V, confere à vítima o direito a indenização pelo dano material, moral ou à imagem. Por outro lado, a Constituição Federal, art. 5º, IX, proclama ser "livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença". Mais adiante, no inciso XIV, assegura "a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional".

6.2.1.1. O caráter autônomo do direito à imagem

O direito à imagem tem caráter autônomo. Com isso queremos dizer que, para ele ser violado, não é necessário que tenhamos, também, violação à honra. O direito à imagem pode ser violado sem que haja violação à honra (ou a privacidade). Nisso consiste o caráter autônomo do direito à imagem. Digamos, por exemplo, que uma universidade privada usou, com grande destaque, em seu material de publicidade, uma foto do rosto de um aluno em *outdoors* e nas mídias sociais. Digamos que não houve autorização do aluno para essa exposição. Houve, aí, violação ao direito de imagem sem que tenha havido violação à honra. A mesma coisa aconteceu em 2017: vários jogadores de futebol processaram produtoras de *games* (e ganharam) em razão direito à imagem. Os *games* foram feitos a partir das imagens de alguns jogadores conhecidos, mas sem as respectivas autorizações.

6.2.1.2. O caráter uno do direito à imagem

O direito à imagem é um só, embora projete diferentes e variados efeitos por todo o ordenamento jurídico. É um direito socialmente relevante, sobretudo nos nossos dias. Embora tenha um caráter uno, a doutrina costuma distinções alguns aspectos projetados por essa unidade conceitual: a) *imagem retrato*: são as características fisionômicas do titular, sua representação visual (tanto no aspecto estático, como uma pintura, como no dinâmico, como um vídeo); b) *imagem atributo*: são

insuficiência das condições legais de encarceramento" (STF, RE 580252, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, julgamento em 16/02/2017). Voltaremos ao tema.

aqueles características de identificação social da pessoa, isto é, a imagem projetada através dos comportamentos habituais de alguém; c) *imagem voz*: diz respeito à identificação de alguém por seu timbre sonoro. A voz de alguém muitas vezes identifica esse alguém, faz parte do que a pessoa é.

6.2.1.3. O caráter in re ipsa do direito à imagem

Os danos à imagem são danos *in re ipsa*. Isso significa que, tendo havido o uso de imagem alheia sem autorização, a indenização será devida, não sendo necessário que se prove ter sofrido prejuízo com o uso indevido. Basta o fato da violação da imagem em si. O dano, nesse sentido, é a própria utilização da imagem. A existência de prejuízo material não é fator relevante. Até mesmo se o ofensor teve prejuízo com o uso indevido da imagem alheia, ainda assim ele deverá indenizar aquele que teve a imagem usada. O mesmo se diga se o ofensor usou a imagem alheia fazendo referências elogiosas. A princípio, o uso sem autorização é indevido e será indenizável[24].

6.2.1.4. A análise da função social da imagem

A imagem deve ser analisada – no contexto de sociedades plurais e complexas – não só sob o ângulo individual, mas também a partir da função social por ela desempenhada. Sobretudo em democracias constitucionais, com amplas liberdades comunicativas, tendo singular relevância o direito de informar e ser informado, como direito fundamental, difuso, de vasta significação social. Se a divulgação tem imagem tem interesse social haverá, pelo menos princípio, o que poderíamos denominar de *função social da imagem*. É claro que isso não é um passaporte para abusos, mas havendo interesse coletivo, social, a regra é a divulgação.

A Constituição de 1988 valoriza a liberdade de imprensa. É atividade preciosa na construção do pluralismo e do debate de ideias, essenciais à democracia. A liberdade de expressão faz parte da tradição constitucional brasileira desde a Constituição do Império, com tristes hiatos, porém, durante o governo Vargas e, mais tarde, na ditadura militar, nos chamados anos de chumbo. Hoje grande parte dos fatos noticiados dizem respeito a crimes. Até se diz que a seção de política dos jornais se misturou com a de polícia. Afirma-se, nesse contexto, que "crimes são fatos noticiáveis por natureza, não podendo ser tratados como questões estritamente privadas. E, por fim, há evidente 'interesse público' na sua divulgação, inclusive como fator inibidor de transgressões futuras"[25].

[24] A respeito da matéria o Enunciado 587 das *Jornadas de Direito Civil* concluiu: "O dano à imagem restará configurado quando presente a utilização indevida desse bem jurídico, independentemente da concomitante lesão a outro direito da personalidade, sendo dispensável a prova do prejuízo do lesado ou do lucro do ofensor para a caracterização do referido dano, por se tratar de modalidade de dano *in re ipsa*". Analisamos os vários aspectos do direito à imagem em outra obra, em longo capítulo, para onde pedimos licença para remeter o leitor, caso haja interesse: FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. *Novo Tratado de Responsabilidade Civil*. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2017.

[25] BARROSO, Luís Roberto Barroso; BARCELLOS, Ana Paula. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Critérios de ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. *RTDC*, vol. 16, out/dez 2003, p. 100.

É certamente delicado o equilíbrio entre o direito de informar e o dever de não agredir a imagem das pessoas envolvidas. Se o exercício diário da liberdade de imprensa garante uma sociedade livre, não é menos certo que não se pode, sob esse pretexto, destruir vidas e tisnar honras. Cabe lembrar que certos aspectos da pessoa pública podem e devem ser noticiados[26]. A liberdade de circulação de ideias e notícias alimenta o espírito democrático, fortalece instituições, sofistica (no bom sentido) o debate, aprimora o espírito crítico. Nossa sociedade alimenta-se continuamente de informações e notícias. Conforme adiante veremos, há interesse público na própria liberdade de informação. Sem falar que não são admissíveis alegações de direito à intimidade quando estão em jogo recursos públicos.

6.2.1.5. Parâmetros de ponderação

Convém mencionar alguns critérios de ponderação – que supomos constitucionalmente consistentes – para tentar chegar a soluções adequadas em relação ao direito à imagem. Mas podemos adiantar desde já. São eles: a) veracidade da informação jornalística; b) personalidade pública ou estritamente privada da pessoa objeto da notícia; c) licitude do meio empregado na obtenção da informação; d) local e natureza do fato; e) existência de interesse público na divulgação; f) preferência por medidas que não envolvam a proibição prévia da divulgação.

Em relação ao primeiro item – *veracidade da informação jornalística* – convém registrar que informação cuja divulgação se protege, portanto, é a informação verdadeira. Informação falsa gera indenização por danos morais, cujo arbitramento variará conforme as circunstâncias. A doutrina, no Brasil e lá fora, reconhece este ponto: "Todos os doutrinadores citados, mesmo os que, em maioria, adotam uma disciplina comum entre expressão e informação, deparam-se com, pelo menos, uma distinção importante entre os dois institutos: a veracidade e a imparcialidade da informação. E é, justamente, em razão dessa distinção fundamental que se deve pensar em um direito de informação que seja distinto em sua natureza da liberdade de expressão"[27]. Deve-se exigir dos órgãos de informação diligência em apurar a verdade, não se admitindo a despreocupação e a irresponsabilidade (em, por exemplo, publicar algo que não resista a uma simples aferição). A jurisprudência recente tem percebido que a liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade

[26] Nesse sentido "não constitui ato ilícito apto à produção de danos morais a matéria jornalística sobre pessoa notória a qual, além de encontrar apoio em matérias anteriormente publicadas por outros meios de comunicação, tenha cunho meramente investigativo, revestindo-se, ainda, de interesse público, sem nenhum sensacionalismo ou intromissão na privacidade do autor" (STJ, REsp 1.330.028). O que é preciso ficar claro é que o uso de imagem de pessoa pública em reportagem jornalística não depende de sua prévia autorização. O STJ, de modo correto, tem entendido que "inexiste ofensa à honra e imagem dos cidadãos quando, no exercício do direito fundamental de liberdade de imprensa, há divulgação de informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito, mormente quando exercida em atividade investigativa a consubstanciar interesse público" (STJ, AgRg no ARESP 224.122). Também decidiu que "o processo de divulgação de informações satisfaz o verdadeiro interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um procedimento judicial" (STJ, REsp 984.803).

[27] CASTANHO DE CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti. *Direito de informação e liberdade de expressão*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 24.

(STJ, REsp 1.414.887)[28]. O que se exige dos veículos de comunicação é que ajam banhados pela boa-fé. Que busquem padrões mínimos de cuidado e zelo, com a constante checagem do que publicam.

Em relação ao segundo ponto – *personalidade pública ou estritamente privada da pessoa objeto da notícia* – sabemos que todas as pessoas (mesmo aquelas de ampla visibilidade, como os políticos nacionalmente conhecidos) têm direito à honra e, embora em grau menor, à privacidade. Ninguém é obrigado a ser político. Quem escolhe dirigir, por qualquer modo, os rumos coletivos do país, deve arcar com os ônus próprios da representação popular. A privacidade do político é nenhuma no que se refira aos negócios públicos, ainda que travestidos de transações privadas. As lentes da imprensa não podem, contudo, de modo desproporcional, se voltar para aspectos da vida do político que só digam respeito a si ou a sua família (dolorosa morte de sua filha, com câncer, por exemplo)[29]. Em 2017 a revista alemã *Bunte* foi condenada a pagar 50 mil euros à família do piloto Michael Schumacher. O piloto sofreu, em 2013, enquanto esquiava, gravíssima lesão na cabeça e desde então a família evita falar na situação. A revista teria dito que em dezembro de 2015 Shumacher teria conseguido dar alguns passos e chamou isso de "milagre de Natal". A família afirmou que a notícia era falsa e que o assunto era estritamente privado.

Em linha de tendência podemos dizer que a informação a respeito da vida privada – sobretudo em se tratando de políticos – poderá ser divulgada quando, de algum modo, contribua para a formação do juízo crítico a respeito da atuação pública da pessoa[30]. Há claro interesse social da sociedade (e do eleitor) em ser bem informado.

[28] Nesse contexto, para não incidir em irresponsável desleixo (gerador do dever de indenizar), o veículo de imprensa deve – quando exerce atividade investigativa – buscar fontes fidedignas, ouvir as diversas partes interessadas e afastar qualquer dúvida séria quanto à veracidade do que divulgará. Isso não quer dizer, no entanto, que se exija certeza plena, com a cognição plena e exauriente própria de um procedimento judicial. É certo que "nem sempre é fácil distinguir entre o verdadeiro e o falso, o que dificulta a aplicação dessa teoria (teoria da busca da verdade) para justificar todo tipo de manifestação do direito de expressão. É o caso, por exemplo, daquelas manifestações que não recaem sobre situações fáticas, mas constituem juízos de valor ou de opinião, cujos conteúdos contém alta dose de subjetividade e, por esta razão, mesmo verdadeiros, podem colidir com outros direitos fundamentais também assegurados na Constituição" (RODRIGUES JÚNIOR, Álvaro. *Liberdade de expressão e liberdade de informação: limites e formas de controle*. Curitiba: Juruá, 2008, p. 67).

[29] Stefano Rodotá sugere critérios interessantes para tais indagações. Sugere que é a própria vida do homem público que deve determinar, no caso concreto, os limites da informação sobre ele publicada. E argumenta que mesmo o homem público tem o sagrado direito de ser resguardada sua vida sentimental ou sexual; a manter sigilo em relação a quem recebe ou frequenta. O mesmo não se pode dizer, contudo, se ele professa um moralismo exasperado e é visto, pela imprensa, em situação que contradiga sua pregação e a de seu partido. Há alguns anos a imprensa americana descobriu que determinado deputado republicano – eleito pela Flórida por seis mandatos e então presidente da Comissão para Crianças Desaparecidas ou Exploradas – era pedófilo. O deputado, após a reportagem, admitiu o fato e disse que era alcoólatra e que havia sido abusado quando criança. Além da óbvia necessidade de divulgação dos crimes de pedofilia, tais informações são ainda mais relevantes pelos contextos do caso: sabemos que o Partido Republicano, assumidamente conservador, prega moral rígida, apresentando-se como bastião dos bons costumes. Foram eles que transformaram aspectos da vida privada e do comportamento familiar dos homens públicos no eixo da política americana. Havendo um abismo entre o dito e o praticado, tal informação é de nítido interesse público dos eleitores.

[30] Nesse sentido, "a redução do âmbito de proteção aos direitos de personalidade, no caso dos políticos, pode em tese ser aceitável quando a informação, ainda que de conteúdo familiar, diga algo sobre o caráter do homem público, pois existe interesse relevante na divulgação de dados que permitam a formação de juízo crítico, por parte dos eleitores, sobre os atributos morais daquele que se candidata a cargo eletivo" (STJ, REsp 1.025.047). O STJ decidiu que o ente público não faz jus à indenização por dano moral por ofensa à imagem. Não cabe, desse modo, pleitear, contra particular, indenização por dano moral relacionado à violação da honra ou da imagem. No caso julgado, apresentadores de programas de rádio imputaram à Secretaria e ao secretário práticas de maus-tra-

Sabemos que não existem, na sociedade contemporânea, direitos absolutos, incondicionados. Também assim ocorre com a liberdade de expressão. Existem períodos e cenários em que se aceita maior virulência na adjetivação e maior aspereza no modo de dizer – como os períodos eleitorais, por exemplo. Mas nem tudo é admissível ou tolerável. Liberdade de expressão não é sinônimo de afirmação irresponsável.

Em relação ao terceiro item – *licitude do meio empregado na obtenção da informação* –, trata-se de algo que poderá ter utilidade, no caso concreto, o modo de obtenção da informação. Porém, mesmo aqui, certas ponderações se impõem. A mesma coisa se diga em relação ao *local e a natureza do fato*. Em se tratando de responsabilidade civil, as respostas serão sempre tópicas, circunstanciais, dependendo dos contornos do caso concreto. É possível, em alguns casos, que mesmo que a notícia provenha de registros públicos, sua divulgação se mostre esvaziada de qualquer interesse social, sendo agressiva aos direitos da personalidade[31]. Convém lembrar ainda que a Constituição Federal preserva o sigilo da fonte jornalística. Prevê o art. 5º, XIV ser "assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional". Em relação aos demais itens – *existência de interesse público na divulgação*[32] e *preferência por medidas que não envolvam a proibição prévia da divulgação* – voltaremos ao tema ainda neste capítulo. Numa sociedade pluralista e democrática, progressivamente complexa, parece-nos que essas orientações – lembrando, em autêntico truísmo, que cada caso é um caso – são as que melhor conciliam os valiosos interesses em jogo.

Não que toda e qualquer notícia ou reportagem precisem trazer o timbre do interesse público. Sabemos que não é nem deve ser assim. Gostamos de notícias curiosas, insólitas, engraçadas. Faz parte da curiosidade humana querer saber um pouco de divertidas amenidades. Nada disso é vedado. O interesse público apenas poderá ser razoavelmente invocado como fator limitador da notícia quando houver, na divulgação, dano à imagem de alguém. Mesmo assim, de modo excepcional e extremamente restrito, presentes as ponderações anteriormente feitas.

tos contra alunos da rede pública. Permitiram, também, que um ouvinte chamasse o prefeito de "ditador". O STJ entendeu basicamente que se trata do exercício de liberdade de imprensa. Sabemos que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula 227). Não, porém, pessoa jurídica de direito público contra particular, o que contrariaria a essência dos direitos fundamentais (STJ, REsp 1.258.389). Embora a fundamentação esteja correta, não se pode negar a possibilidade de abusos. E as portas das sanções civis não devem estar inteiramente fechadas a esses abusos. Seria incorreto, por exemplo, negar ao ocupante de função pública (secretário de educação, no caso), o direito de postular a compensação moral.

[31] Nessa ordem de ideias, a "simples reprodução, por empresa jornalística, de informações constantes na denúncia feita pelo Ministério Público ou no boletim policial de ocorrência consiste em exercício do direito de informar". Relativiza, porém, o Tribunal: "Na espécie, contudo, a empresa jornalística, ao reproduzir na manchete do jornal o cognome – apelido – do autor, com manifesto proveito econômico, feriu o direito dele ao segredo da vida privada, e atuou com abuso de direito, motivo pelo qual deve reparar os consequentes danos morais" (STJ, REsp 613.374).

[32] Podemos adiantar que "onde a crítica há de ter latitude especialmente ampla é no campo da 'atuação das instâncias públicas" (PEREIRA, Guilherme Döring Cunha, *Liberdade e Responsabilidade dos Meios de Comunicação*. São Paulo: RT, 2002, p. 244/245).

6.2.1.6. Direito ao esquecimento: contextualização e dificuldades

"Nós vivemos a temer o futuro;
mas é o passado quem nos atropela e mata."

Mário Quintana

O direito ao esquecimento é tema novo e cercado de perplexidades. Trata-se, em suma, de impedir que episódios e fatos do passado ressurjam no presente, atrapalhando a vida de alguém. O poeta certa vez ironizou que o problema do passado é que ele não passa, continua nos infernizando. Ironias à parte, o tema está muito ligado às tecnologias de massa, seja na imprensa tradicional, seja na internet. Teríamos o direito de impedir que o passado retorne ao presente, sobretudo se modo descontextualizado e desconforme à realidade? Podemos exigir que o passado não nos siga para sempre, pelo menos na internet? As perguntas são muitas e complexas. Qual o espectro de incidência do direito ao esquecimento? Abrangeria qualquer fato ocorrido no passado que incomodasse alguém? O assunto ficaria como que proibido de ser reavivado por qualquer membro da sociedade? Haveria um lapso temporal para se pleitear o respeito ao direito de esquecer?

O tema é delicado e despertará cada vez mais a atenção dos estudiosos. Já sabemos que soluções apriorísticas dificilmente satisfazem. A ponderação de interesses deverá ser mais uma vez convocada para atuar. O STJ já frisou, nesse sentido, que "o direito ao esquecimento do ofensor (...) deve ser ponderado pela questão da historicidade do fato narrado, assim também o direito dos ofendidos deve observar esse mesmo parâmetro" (STJ, REsp 1.335.153). Na mesma – e correta, pelo menos em tese – linha argumentativa ponderou que "a história é patrimônio imaterial do povo e nela se inserem os mais variados acontecimentos e personagens capazes de revelar, para o futuro, os traços políticos, sociais ou culturais de determinada época" (STJ, REsp 1.334.097). A historicidade dos fatos, cremos, deverá ser analisada em concreto, e sopesada com os interesses individuais. Só em casos realmente raros, excepcionais, a tese poderá ser aceita diante de nossas democracias constitucionais que valorizam tão amplamente a liberdade de informação e de comunicação.

A jurisprudência brasileira começa a se defrontar com o problema. O STJ entendeu que gera dano moral a veicução de programa televisivo acerca de fatos antigos, com ostensiva identificação de pessoa que tenha sido investigada e, posteriormente, inocentada em processo criminal (STJ, REsp 1.334.097, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T, DJ 10/09/2013). É preciso certo cuidado com a orientação, que pode ser adequada em alguns casos, mas certamente não o será em todos. A tendência da sociedade contemporânea é não transigir com proibições de veiculação de informações ou reportagens, sob qualquer verniz ou pretexto (sobretudo vedações prévias devem ser evitadas).

Não é algo democraticamente saudável, ainda que sejam invocáveis luminosos argumentos. Há, no caso, a referência à absolvição criminal – dado que é realmente relevante e pode particularizar esse caso diante de outros, ainda que, muitas

vezes, diante das notórias deficiências da justiça criminal, a absolvição por falta de provas nem sempre tranquilize a sociedade, que vê aí não o atestado de boa conduta do suspeito, mas apenas a permeabilidade judicial a influências outras, marcadas pelo poder econômico, pelas relações sociais, ou, quando menos, pela notória ineficiência do sistema judiciário. Seja como for, em linha de princípio, na sociedade da informação não se deve tentar abafar a circulação da informação. Deve-se, porém, isso sim, sancionar civilmente os abusos, que são atos ilícitos (Código Civil, art. 187).

As liberdades comunicativas podem ser seriamente abaladas se a tese do direito ao esquecimento for aceita com amplitude. Não parece ser esse o melhor para nossa jovem democracia constitucional. Sobretudo nos fatos que digam respeito ao interesse público, parece pouco recomendável que alimentemos excessivamente a tese do direito ao esquecimento. O STF, nos últimos anos, tem caminhado no sentido oposto (lembremos, por exemplo, da decisão que tornou desnecessária a autorização do biografado, ou daquela que afastou a proibição do humor nas eleições, dentre outras). A memória coletiva, e a própria liberdade de expressão e de informação, precisam de ventos mais livres, de janelas abertas e corredores amplos por onde possam passar.

A questão, enfim, talvez não seja tão simples como parece (talvez, na verdade, sequer *pareça* simples). Podemos inserir variáveis que tornam ainda mais delicado o problema: o direito ao esquecimento englobaria qualquer pessoa, pública ou privada, qualquer que seja ou tenha sido sua trajetória ou função? Problematizemos a questão. Um político, por exemplo, poderia tentar retirar na internet investigações e acusações que existiram contra ele, ainda que tenha havido a absolvição ou que elas nunca tenham sido formalizadas judicialmente? O eleitor não teria direito a essa informação? Ou, suponhamos, mesmo alguém que nunca tenha postulado um cargo de representação pública, poderia, digamos, "limpar" esse passado e, só depois, postular um cargo eletivo?[33]

As respostas exigem contextualização e não toleram, em absoluto, generalismos retóricos. Aliás, no *leading case* julgado pelo STJ e acima citado, isso é reconhecido com explicitude: "No caso, o julgamento restringe-se a analisar a adequação do direito ao esquecimento ao ordenamento jurídico brasileiro especificamente para o caso de publicações na mídia televisiva, porquanto o mesmo debate ganha contornos

[33] Existem hoje empresas de mídia especializadas (por exemplo, lá fora, *reputationdefender* e *reputation.com*) em produzir conteúdo positivo na internet a respeito de alguém, e com isso direcionar os sites de buscas, através de mecanismos específicos, para esses conteúdos positivos (e fabricados, por assim dizer, mediante paga), e não para os outros. Trata-se de prática lícita, não há problema jurídico no serviço prestado (embora possa até se questionar, sob o prisma ético, a adequação da medida). O problema do direito do esquecimento é outro. Trata-se de *retirar* determinados conteúdos, ou *impedir* que eles sejam exibidos (ou, o que é semelhante, sancionar civilmente a sua exibição). Numa versão menos radical, e aplicável apenas à internet, seria desindexar determinados fatos de determinadas pessoas, nos serviços de busca. A doutrina anota: "Nesta dimensão informacional e, mais notadamente, na interseção entre as dimensões informacional e decisional, onde se encontra o direito ao esquecimento, tem-se uma das mais polêmicas discussões do Direito Privado atual. O contemporâneo direito ao esquecimento, reconhecido pelas legislações comunitárias europeias e recepcionado pela doutrina e jurisprudência em outros países, como o Brasil, conflita fortemente com o direito à informação, sobremodo quando aplicado à internet, na qual o fluxo rápido e quase desimpedido de dados é a maior característica" (EHRHARDT JR., Marcos; ACIOLI, Bruno de Lima. Privacidade e os desafios de sua compreensão contemporânea: do direito de ser deixado em paz ao direito ao esquecimento. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de; TEPEDINO, Gustavo (Coord.). *Autonomia privada, liberdade existencial e direitos fundamentais*. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 151-166, p. 164).

bem diferenciados quando transposto para internet, que desafia soluções de índole técnica, com atenção, por exemplo, para a possibilidade de compartilhamento de informações e circulação internacional do conteúdo, o que pode tangenciar temas sensíveis, como a soberania dos Estados-nações". Digamos apenas que ainda que aceitemos que o direito ao esquecimento deve ser amplamente aceito sob o prisma jurídico, talvez haja dificuldades para efetivar essa orientação no mundo digital. Não será fácil. A internet não parece gostar de esquecer.

6.2.2. Direito ao nome

> *"Com uma letra que não digo começa o nome do meu bem, que é todo o mal de minha vida".*
>
> Rubem Braga

> *"Gosto do nome Luísa. Talvez prefira Ana Luísa, não sei. Gosto do nome Júlia. Hoje, quando andava pela Gonçalves Dias, uma jovem Júlia voltava do colégio, tocou o interfone e disse: 'É a Júlia'. Gosto de Letícia. Acho que nunca conheci uma Letícia. Minto, conheci, mas só de longe, quase não conhecendo. Gosto de Beatriz. Terei uma filha chamada assim? Quando estivesse bravo, chamaria o nome todo, e ela saberia que fez algo errado. Mas duraria pouco. Sempre, quase sempre, seria um pai fácil de enganar, caindo de carinho. Bia, desde pequena, saberia pôr o pai no bolso. Gosto de Bruna, meu irmão acha Larissa muito bonito. Eu acho que também acho. Eu acho muitas coisas, é bom nem achar tantas. Falando nisso, qual será, meu amor, o seu nome?".*
>
> (Felipe Braga Netto, em crônica de 2007).

Pontes de Miranda escreveu que o nome cola-se, por bem dizer, à pessoa. Trata-se de direito da personalidade de singular relevância. Muito do nosso percurso existencial, familiar, afetivo, histórico, está ligado ao nome. Nosso passado e nossas heranças culturais estão, também, conectados ao nome. A vida social exige que todos nós tenhamos nomes. Temos, na literatura, singulares enredos e fortes canções cujos enredos e inspirações estão intimamente ligados aos nomes. Há nomes, aliás, que nos acompanham, que não esquecemos jamais.

O Código Civil de 1916 não previu o direito ao nome. O Código Civil de 2002, ao contrário, prevê no art. 16: "Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome". O Pacto de São José da Costa Rica – Convenção Americana de Direito Humanos – prevê em seu art. 18: " Toda pessoa tem direito a um prenome, e ao nome de seus pais ou de um deles. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário". No Brasil, qualquer dos pais pode, em cartório, registrar o nascimento de seu filho, indicando-lhe um nome civil (Lei n. 13.112/2015). Importante lembrar que a Lei n. 13.484/2017 previu: "Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados

ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas" [34].

A Lei n. 9.534/97 dispõe que não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. A Constituição Federal, aliás, no art. 5º, LXXVI, dispõe que serão gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. A disciplina do direito ao nome encontra-se não só no Código Civil, mas também na Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73, com alterações posteriores). Conforme veremos, o nome compreende o prenome e o sobrenome (embora se note, com frequência, na própria lei, confusões. Usa-se o termo "nome", ora para se referir ao nome completo, ora para se referir apenas ao sobrenome). Lembremos que as pessoas jurídicas também têm direito ao nome. O uso indevido do nome (da pessoa natural ou jurídica) pode gerar danos de ordem patrimonial ou extrapatrimonial. A hipótese é de responsabilidade objetiva, não sendo exigível culpa na utilização indevida de nome alheio. Trata-se de dano *in re ipsa*.

6.2.2.1. As funções do nome

O nome da pessoa humana não desempenha, apenas, na sociedade, uma função unidimensional. Há vários aspectos ou várias dimensões que poderiam ser mencionados, como relevantes na espécie. Vejamos, apenas, de modo breve, alguns deles.

6.2.2.1.1. O nome como direito da personalidade

> *"Agora vamos falar de Paulinho da Viola. O que sentimos, diante de sua figura, é que não podia ser Paulo, simplesmente Paulo, em hipótese nenhuma. O diminutivo é obrigatório. E tem um ar de menino, uma delicada tristeza que começou decerto na infância profunda. Experimentamos também a sensação de que há, nesse rapaz magro, lágrimas ainda não choradas".*
>
> Nelson Rodrigues

O direito ao nome insere-se, sem dúvida, entre os direitos da personalidade. Na experiência nazista, um dos primeiros direitos que o prisioneiro perdia – nos campos de concentração – era o de ser chamado pelo nome. O escritor Primo Levi, no livro *É isto um homem?*, narra como, logo que chegavam, os prisioneiros ficavam numa fila para serem marcados, a ferro quente, com um número, e daí em diante

[34] A Lei n. 13.484, de 2017, alterou a Lei de Registros Públicos e formulou também a seguinte autorização: "A naturalidade poderá ser do Município em que ocorreu o nascimento ou do Município de residência da mãe do registrando na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, e a opção caberá ao declarante no ato de registro do nascimento". A lei reconheceu uma situação já muito comum no Brasil. O nascimento em cidades próximas àquela em que os pais residem (às vezes por razões circunstanciais, como ausência de hospital nesse ou naquele município). Era necessário, nesses casos, autorização judicial para o registro (que era, na verdade, sempre concedida). A lei facilitou (corretamente) esse caminho.

tudo era feito em razão do número, jamais pelo nome. Essa não foi a única maneira cruel que o nazismo adotou para desumanizar os judeus[35]. Baixou-se também uma ordem impondo às mulheres judias a adoção obrigatória, em seus documentos, de um mesmo nome para todas, *Sarah*[36].

Há, nesse contexto, uma fundamental dimensão personalística no nome. Ele contribui para a formação da personalidade. Discutia-se, no passado, qual a natureza jurídica do nome. Havia quem defendesse – em posição hoje superada – que se tratava de direito patrimonial, a exemplo do direito de propriedade (*o nome como direito patrimonial*). Basta lembrar, para evidenciar o desacerto dessa concepção, que o nome da pessoa humana é inalienável. Outras concepções, mais atuais, enxergam no nome um direito extrapatrimonial, com dimensões (aí sim) não apenas patrimoniais, mas também existenciais (*o nome como direito extrapatrimonial*)[37]. Poderá, por certo, haver indenizações pelo uso indevido do nome alheio, mas isso não torna patrimonial o que é, por essência, extrapatrimonial (já abordamos o problema). Ainda em relação ao nome como direito da personalidade não pode ser esquecida a relevante função que o nome desempenha na formação dos caracteres psicológicos, reforçando a autoimagem de cada um de nós. O nome é, em muitos aspectos, uma história de vida, um percurso existencial, um acervo de memórias, afetos e passados.

6.2.2.1.2. O nome como sinal designativo

Além da dimensão do nome como direito da personalidade há outra: aquela que permite que o nome funcione como sinal designativo no meio social. Nesse aspecto, o nome desempenha função de mecanismo identificador, possibilitando a designação diferenciada das pessoas. Pontes de Miranda ensina que "a história e o caráter do povo refletem-se, de certo modo, nos nomes que inventou. As invasões e as guerras inscrevem-se neles, as suas classes sociais revelam-se, bem como as suas qualidades de espiritualidade (*e.g.*, nos nomes gregos, Sófocles, Péricles, Aristo, Poliarco...)". Um pouco antes observa: "No velho direito germânico, bastava um

[35] Hannah Arendt valeu-se da expressão "direito a ter direitos" para mencionar o direito à cidadania, esvaziado ou mutilado por regimes totalitários – em especial pelo nazismo –, que suprimiam a nacionalidade das pessoas de virtude de questões étnicas ou políticas. Conferir: ARENDT, Hannah. *Origens do totalitarismo*. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. Aliás, os nazistas "sentiam genuíno desprezo, jamais abolido, pela estreiteza do nacionalismo e pelo provincianismo do Estado-nação" (p. 26).

[36] Cf. MORAES, Maria Celina Bodin de. Sobre o nome da pessoa humana. *Revista da Emerj*. Rio de Janeiro, v. 3, n. 12, 2000, pp. 48-74.

[37] Sendo o o nome civil um direito da personalidade, convém apresentar algumas de suas características mais relevantes, inerentes à sua condição personalíssima. Nesse contexto, o direito ao nome civil é: *i) absoluto* (produzindo efeitos *erga omnes*); *ii) obrigatório* (o art. 50 da Lei nº 6.015/73 proclama a necessidade de registro civil de todas as pessoas nascidas, inclusive os natimortos); *iii) indisponível* (uma vez que não pode o *titular* ceder, alienar, renunciar, dentre outras formas de disposição); *iv) exclusivo* (característica inerente, apenas, à pessoa jurídica, uma vez que impossível de ser aplicada à pessoa natural, a quem se permite a homonímia); *v) imprescritível* (não sendo possível perder o nome pelo não uso); *vi) inalienável* (reconhecida a impossibilidade de a pessoa humana vender ou dar o seu nome como decorrência lógica da própria impossibilidade de dispor da própria identificação pessoal. No entanto, não se olvide que a pessoa jurídica poderá dispor de seu *nome de fantasia*, que se trata de elemento componente de seu patrimônio); *vii) incessível* (caráter privativo, também, da pessoa natural, inaplicável à pessoa jurídica); *viii) inexpropriável* (não sendo suscetível de desapropriação pelo Poder Público, salvo em se tratando de nome de pessoa jurídica, em face de seu conteúdo patrimonial); *ix) irrenunciável* (salvo casos especiais, em que se admite o despojamento de parte do nome); *x) intransmissível* (consequência da indisponibilidade).

nome para individualizar, para pessoalmente identificar. A tentativa gregoriana de circunscrever os nomes àqueles dos santos encontrou a imaginação criadora do povo, que continuou enriquecendo as línguas e a traduzir, na escolha dos nomes, simpatias étnicas, guerreiras, revolucionárias, filosóficas e políticas. O duplo nome prende-se ao século XII"[38]. Entre as funções do nome está a designativa, que serve diferenciar a pessoa na sociedade, peculiarizá-la através de um signo gráfico. Por isso, os homônimos trazem tantos transtornos para seus portadores na vida social (há muitos e lamentáveis casos, sobretudo envolvendo pessoas humildes, de prisões por engano, por exemplo).

6.2.2.2. A simplificação operada pelo Código Civil

O Código Civil de 2002 simplificou a disciplina do nome. Com essa salutar simplificação, perdem relevância os exageros formais do passado, que distinguiam várias espécies (agnome, axiônimo, cognome etc.). Segundo o Código Civil, art. 16, nome é formado de prenome e sobrenome ("Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome"). Outro aspecto que deve ser mencionado é que não se admite, no direito brasileiro, o uso de títulos nobiliários ou honoríficos para compor o nome (como Duque, Condessa etc.). Quando do casamento, é possível que qualquer dos noivos suprimam nomes de família, desde que não haja prejuízo à ancestralidade (identificação da família), nem à sociedade, pois o nome civil é direito da personalidade. O Código Civil admite que qualquer dos noivos acrescente ao seu o sobrenome do outro (art. 1.565, § 1º). A ex-mulher pode manter o nome do ex-marido, mesmo contra a vontade deste, desde que possa haver prejuízo ao direito à identidade com a supressão, mas não só isso. O nome como direito da personalidade deve ser levado em conta também nesse caso.

6.2.2.3. Registros públicos: o princípio da inalterabilidade relativa do nome

Os registros públicos buscam, fundamentalmente, espelhar a realidade da vida. Há uma pretensão de veracidade quanto aos fatos (não só quanto ao nome das pessoas, mas quanto ao estado e demais situações relevantes que devam ser objeto de registro público). Nem sempre o registro traduz com exatidão o fato social, mas essa é a linha de tendência a ser buscada. O STJ já percebeu que "é verdade que, conforme a lei, é imutável o nome. Mas imutável dever ser o nome pelo qual é a pessoa socialmente conhecida, não aquele com o qual fora ela registrada" (STJ, REsp 213.682). Por outro lado, precisamos, culturalmente, nos libertar dos excessos burocráticos e cartorários da tradição ibérica que não fazem mais sentido no século XXI, numa sociedade ágil e cada vez mais digital[39]. Em relação ao nome, a regra, convém lembrar, é sua imutabilidade (relativa, não absoluta). Isso vale tanto para o prenome como para o sobrenome. Há, porém, em certos casos, espaço para modificações. É o que veremos

[38] PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*. T. I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p. 238.

[39] Os registros públicos têm precedentes históricos na alta Antiguidade, passando pelo direito da Grécia, de Roma e da Idade Média. Podemos, menos remotamente, conectá-los culturalmente aos registros paroquiais da Igreja Católica, que especialmente a partir do século XIV registravam os batismos, os casamentos e as mortes. Francisco Amaral, nesse contexto, esclarece que "o registro civil é a instituição administrativa que tem por objetivo imediato a publicidade dos fatos jurídicos de interesse das pessoas e da sociedade. Sua função é dar autenticidade, segurança e eficácia aos fatos jurídicos de maior relevância para a vida e os interesses dos sujeitos de direito" (AMARAL, Francisco. *Direito Civil. Introdução*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 245). Convém, a propósito, distinguir registro de averbação. Registra-se, por exemplo, os nascimentos, casamentos e óbitos (Código Civil, art. 9º). A averbação tem, em relação ao registro, caráter acessório, alterando-o. É realizada em relação ao registro já existente. Averba-se, por exemplo, as sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial etc (Código Civil, art. 10, I). Uma mudança de nome, por exemplo, judicialmente determinada, será caso de averbação.

[40] A propósito, houve épocas, na história, de fartura de nomes, e outros ciclos históricos menos criativos nesse sentido. Assim, "à diferença do *luxo de nomes* dos Romanos, os séculos medievais e imediatamente pós-medievais foram caracterizados pela pobreza de nomes. Poucos nomes têm as pessoas e quase sempre um só, com alguma alcunha ou apelido profissional" (PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*. T. I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p. 239).

[41] Assim "é que se encontram, com facilidade, pessoas que portam prenomes causam gozações, brincadeiras vexatórias e insinuações pejorativas, os quais configuram verdadeiras violações à cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana" (MORAES, Maria Celina Bodin de. A tutela do nome da pessoa humana. *Revista Forense*. Vol. 364, Rio de Janeiro, 2002. (novembro/dezembro); pp. 217/228, p. 221.

a seguir. Se o nome das pessoas naturais pudesse ser alterado a qualquer tempo, por mero capricho, estaria seriamente arranhada a segurança jurídica. Alguma estabilidade se faz necessária, por isso a ordem jurídica prevê que em regra não se pode alterar o nome, aceitando, no entanto, exceções. Vejamos hipóteses de alteração do prenome.

6.2.2.3.1. Erro gráfico evidente

O escritor Millôr Fernandes sempre contou que seu nome deveria ser Milton. O oficial, porém, ao efetuar o registro, por descuido não completou o traço horizontal que caracteriza a letra "t" (lembremos que os registros não eram feitos, no passado, por computador). Ficou Millôr, e não Milton. O que acabou sendo bom, trazendo um nome diferenciado ao também peculiar escritor e chargista[40]. O caso, porém, simboliza bem o que tentamos dizer neste item. Se houver um erro de grafia (Gerardo, ao invés de Geraldo, por exemplo), a mudança é possível.

6.2.2.3.2. Prenomes ridículos

A Lei nº 6.015/73, que dispõe sobre os Registros Públicos, proíbe (art. 55) que os oficiais procedam ao registro de prenomes ridículos. Embora os oficiais de registro devam se recusar a registrar os nomes ridículos, sabemos que eles existem, e continuarão a existir. São risíveis os absurdos em que certos pais incorrem, não fossem trágicos para os filhos ("Primeira Delícia Azevedo", "Colapso Cardíaco da Silva", "Naída Navinda Navolta Pereira", "Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado", "João Cara de José", "Joaquim Pinto Molhadinho", "João Casou de Calças Curtas" – todos, acreditem ou não, reais). Sabemos que os danos daí advindos, principalmente em fase escolar, são irrecuperáveis, gerando, potencialmente, graves abalos psíquicos[41]. Configurada a hipótese, os filhos, atingida a maioridade ou antes, através de curador especial, poderão acionar civilmente os pais, exigindo-lhes compensação moral. Não se exclui a responsabilidade solidária do oficial que realizou o registro. O art. 28 da Lei de Registros Públicos dispõe: "Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro".

Naturalmente, nos casos de nomes ridículos, a negligência do oficial é evidente. Aliás, mesmo que inexistisse o art. 28, o oficial poderia ser solidariamente responsável junto com os pais, eis que a solidariedade é a regra em se tratando de responsabilidade civil (Código Civil, art. 942). Nesses casos, sempre que possível, não se deve aguardar a maioridade civil (hipótese que adiante mencionaremos) para solicitar a alteração. A tutela dos direitos da personalidade deve ser preferencialmente preventiva. Deve-se evitar o dano, ou a continuação de seus efeitos. Lembremos, a propósito, que o CPC/2015 dispõe, art. 72: "O juiz nomeará curador especial ao: I – incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade". O parágrafo único do artigo citado prevê que a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.

6.2.2.3.3. Adoção

A matéria era disciplina pelo Código Civil no art. 1.627 e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no art. 47, § 5º – dispositivos revogados pela Lei n. 12.010/2009. Não houve, no entanto, modificação de vulto. Diz a lei em vigor que "a sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome" (redação atual do ECA, art. 47, § 5º). Estabelece, a seguir, que "caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei". Os referidos parágrafos estabelecem: sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Tratando-se de maior de 12 anos, será necessário seu consentimento, colhido em audiência.

6.2.2.3.4. Apelidos públicos notórios

Trata-se de hipótese já tradicional em nosso direito civil de alteração do prenome. Aliás, a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) foi alterada (pela Lei n. 9.708/98) especialmente consignando esta hipótese: "O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios". Esclareça-se não são apenas pessoas famosas que fazem jus a essa alteração. O conceito de "apelido público notório" (chamado, por alguns, de *hipocorístico*), aí, é entendido no ambiente comunitário de cada cidadão. Assim, se determinado indivíduo é conhecido, em sua comunidade, como "Zé do Parafuso", trata-se de apelido público notório que pode ser acrescido ao prenome, ou mesmo inserido no lugar do prenome, com a supressão deste. O mesmo se diga em relação ao uso prolongado e constante de nome diverso (uma mulher que ficou conhecida por Maju, e não Marialva, que é seu nome no registro). É certo que o nome nos acompanha e deixa pegadas, marcas[42].

[42] Costuma-se cogitar que Shakespeare teria sido um dos tradutores da Bíblia para a língua inglesa (mais especificamente, a famosa *King's James Bible*). As pistas, argumenta-se, teriam sido deixadas pelo próprio poeta. No Salmo 46. Se contarmos, a partir do início desse Salmo, 46 palavras, vamos encontrar a palavra *"Shake"*. Se contarmos, do final para o início, 46 palavras, vamos encontrar a palavra *"spear"*. Ambas formam Shakespeare. A coincidência é realmente incrível (SCHNAKENBERG, Robert. *A vida secreta dos grandes autores*. Rio de Janeiro: Ediouro, 2008, p. 10; FELLOWS, Virginia M. *O Código Shakespeare*. Rio de Janeiro: Bestseller, 2010. Ver ainda o excelente *Medida por medida: o direito em Shakespeare*, do arguto Professor José Roberto de Castro Neves, pensador seguro e original. Rio de Janeiro: Edições Janeiro, 2016).

6.2.2.3.5. Fundado temor em razão de colaboração com apuração de crimes

Também é possível a alteração do nome (e não só do prenome) em caso de inclusão no programa de proteção a testemunhas. Mesmo que não haja, a rigor, inclusão no referido programa (cujos pressupostos são rígidos e rigorosos, e de cumprimento obrigatórios pelo protegido, na forma da Lei n. 9.807/99), a alteração também é possível, já que a lei dispõe de modo amplo que a "substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério Público" (art. 58, parágrafo único, da Lei nº 6.015/73 com redação dada pela Lei n. 9.708/98). Observe-se que a redação dada pela Lei n. 9.708/98 apenas menciona a alteração do prenome (o que seria inócuo), mas a Lei n. 9.807/99, em seu art. 9º, admite a alteração do nome completo. Entendemos que em qualquer dos casos, com ou sem inclusão formal no programa de proteção à testemunha, a alteração do nome – judicialmente determinada – poderá ser do nome completo, e não só do prenome. A alteração, no caso, poderá ser temporária ou definitiva, dependendo do caso concreto, da continuidade ou não das ameaças e dos temores fundados à integridade física e moral da testemunha e de seus familiares (o programa de proteção à testemunha tem duração máxima de dois anos, podendo ser prorrogado, na forma do art. 11 da Lei n. 9.807/99). De toda sorte, a alteração do nome será preferencialmente temporária.

6.2.2.3.6. Possibilidade de alteração imotivada do nome aos 18 anos

Estamos diante de hipótese que dispensa motivação ou justificativa. Trata-se de situação normativa pouco conhecida – que, talvez, se mais conhecida, fosse mais usada. Qualquer um de nós, completados 18 anos de idade, pode alterar o prenome, sem motivar esse desejo (uma rara hipótese de *mudança imotivada*). A partir da aquisição da capacidade civil – embora tenhamos mencionado 18 anos acima, devemos entender: 18 anos ou emancipação –, inicia-se o prazo decadencial de 1 ano para que o titular possa alterar seu nome, sem qualquer justificativa. É o que prevê a Lei de Registros Públicos no art. 56. Embora se trate de previsão antiga (de 1973), anterior à Constituição de 1988, é norma que se harmoniza com a concepção que enxerga no nome um direito de personalidade. Respeita-se a autonomia da pessoa, suas escolhas e seu percurso existencial. Abre a possibilidade que a própria pessoa redefina sua trajetória em algo bastante importante como é o nome. Trata-se, sem dúvida, de *escolha existencial fundamental*, das mais relevantes.

6.2.2.3.7. Naturalização do estrangeiro

O estrangeiro, naturalizado brasileiro, pode, se desejar, alterar o prenome. Trata-se, na verdade, de hipótese que objetiva facilitar a adaptação do estrangeiro (agora brasileiro) ao seu novo país. Se, digamos, tinha um prenome de difícil pronúncia

entre nós, poderá, desejando, optar por outro mais fácil, ou mesmo, digamos assim, torná-lo mais brasileiro (e não só mais português). Aliás, não só isso. Também o brasileiro que adquiriu dupla cidadania pode ter seu nome retificado no registro civil do Brasil (STJ, REsp 1.310.088). A mudança, claro, não pode causar prejuízos a outrem e decorre dos transtornos gerados por ter documentos estrangeiros com sobrenome diferente do que consta nos documentos brasileiros.

6.2.2.3.8. Cirurgias de redesignação sexual

Hoje, tal cirurgia é custeada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os médicos não precisam mais, como no passado, de autorização judicial para realizá-la (a própria Resolução n. 1.955/2010 do Conselho Federal de Medicina autoriza essa cirurgia, designando-a de transgenitalismo). Na mudança de sexo, há, em verdade, mudança de estado da pessoa. O registro civil, nesse sentido, poderá ser alterado. O STJ assim se manifestou, julgando caso de pessoa que se submeteu à cirurgia de redesignação sexual: "Existindo, portanto, motivo apto a ensejar a alteração para a mudança de sexo no registro civil, e a fim de que os assentos sejam capazes de cumprir sua verdadeira função, qual seja, a de dar publicidade aos fatos relevantes da vida social do indivíduo, forçosa se mostra a admissibilidade da pretensão, devendo ser alterado seu assento de nascimento a fim de que nele conste o sexo feminino, pelo qual é socialmente reconhecido" (STJ, REsp 1.008.398). O acórdão, aliás, ponderou que a mitigação do sofrimento humano deve ser o sustentáculo de decisões judiciais, no sentido de salvaguardar o bem supremo e o foco principal do direito: o ser humano em sua integridade física, psicológica, socioambiental e ético-espiritual. Hoje aliás se admite não só – no caso de quem passou por cirurgia de redesignação sexual – a mudança do nome, admite-se também a mudança do gênero (de homem para mulher, por exemplo, no registro).

É preciso atentar para importante mudança: em 2017 o STJ deu um passo além. Admitiu a retificação do registro de nascimento para troca de prenome e do sexo (por exemplo, mudança de gênero no registro civil, de masculino para feminino), sem que para isso seja necessária a realização de cirurgia de transgenitalização (STJ, REsp 1.626.739). O STJ argumentou que "o chamado sexo jurídico (aquele constante no registro civil de nascimento, atribuído, na primeira infância, com base no aspecto morfológico, gonádico ou cromossômico) não pode olvidar o aspecto psicossocial defluente da identidade de gênero autodefinido por cada indivíduo, o qual, tendo em vista a *ratio essendi* dos registros públicos, é o critério que deve, na hipótese, reger as relações do indivíduo perante a sociedade".

6.2.2.4. O caráter exemplificativo do rol de mudanças: cláusula aberta

> *"Esse processo de nomeação lembra um velho hábito de Clarice: quando menina, no Recife, ela costumava dar nomes a todos os azulejos do banheiro".*
>
> (Benjamin Moser, biógrafo de Clarice Lispector)

O rol mencionado é puramente exemplificativo. Não exaure as possibilidades de mudança do nome. Deve ser deferida, em regra, a modificação do prenome quando

atendidos, cumulativamente, estes dois requisitos: a) há melhora na situação social ou psíquica do interessado; b) não há prejuízos a outrem. A dignidade humana – e a cláusula que postula o livre desenvolvimento da personalidade humana –, além da solidariedade social, devem iluminar a solução das controvérsias nesse campo. É conhecido o caso do filho que, tendo sido abandonado pelo pai, postulou a supressão do sobrenome deste – que, aliás, nunca tinha usado. A pretensão foi corretamente deferida. O STJ frisou: "O nome pode ser modificado desde que motivadamente justificado. No caso, além do abandono do pai, o autor sempre foi conhecido por outro patronímico" (STJ, REsp 66.643 – o julgado, aliás, citou a "lógica do razoável" que deve imperar nesse campo, algo que mencionamos no primeiro capítulo desta obra). Em outro caso, uma garota pediu para acrescer, ao seu, o sobrenome do padrasto que a havia criado (posteriormente, o legislador editou lei nesse sentido). Alegava não só o intenso vínculo afetivo com aquele que exercia a função socioafetiva de pai, como também se ressentia por não ter o mesmo sobrenome dos irmãos mais novos, que vieram depois dela. Igualmente nesse caso a pretensão foi corretamente deferida. Em 2018 o STJ reconheceu ser possível o restabelecimento do nome de solteiro na hipótese de dissolução do vínculo conjugal pelo falecimento do cônjuge (STJ, REsp 1.724.718). A lei apenas permite a hipótese da retomada do nome de solteiro em caso de divórcio, mas obviamente nada impede que haja o retorno ao nome de solteiro também em caso de morte do cônjuge.

É fácil notar que devemos observar uma *interpretação não exaustiva das hipóteses modificativas do nome*. O juiz, à luz do caso concreto, em procedimento de jurisdição voluntária, de competência da vara de registros públicos, analisará as hipóteses – sobretudo guiando-se pelos princípios constitucionais normativos que mencionamos. Uma das manchetes da *Folha de São Paulo* de 05/12/2017 estampava: "Casal de empresários batiza filho com nome de uma letra só; ele se chama B". Certamente essa criança poderá, mais adiante, caso queira, mudar de nome.

6.2.2.5. Exceções: hipóteses de alteração do sobrenome

Não só o prenome pode ser alterado. A imutabilidade é a regra, como vimos[43]. Às vezes, porém, substanciosas razões levam à alteração do prenome; outras, à alteração do sobrenome. Vejamos, sumariamente, algumas delas: a) *casamento* (ou *união estável*): atualmente, em virtude do casamento, qualquer dos cônjuges pode mudar o sobrenome. Poderá, nesse sentido, acrescer ao seu o do outro, e até eventualmente retirar algum sobrenome que portava. O mesmo vale para a união estável ou homoafetiva; b) pela *separação judicial, dissolução do casamento* ou *da convivência*: também poderá haver alteração, podendo qualquer dos cônjuges voltar a usar o nome que possuía antes de casar (Código Civil, art. 1.571, § 2º; art. 1.578); c) *adoção* (ECA, art. 47, § 5º): conforme já frisamos, na adoção a mudança do sobrenome

[43] Nem sempre os nomes tiveram a imutabilidade que têm hoje. Não só os sobrenomes eram alterados, como havia várias grafias possíveis para cada nome. Cf. HONAN, Park. *Shakespeare: Uma vida*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 91; FRANCO, Gustavo. *Shakespeare e a economia*. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 19; CASTRO NEVES, José Roberto. *Medida por medida: o direito em Shakespeare*. Rio de Janeiro: Edições Janeiro, 2016, p. 39.

necessariamente ocorrerá, enquanto que a mudança do prenome poderá ocorrer (em relação à mudança de prenome, se o adotado tiver mais de 12 anos de idade, exige-se o seu consentimento; se tiver menos de 12 anos, deverá ser ouvido, mas a sua manifestação não vincula o magistrado); d) se houver *fundado temor em razão de colaboração com apuração de crimes*: à luz das normas jurídicas já mencionadas, poderá haver a mudança não só do prenome, mas também do sobrenome; e) *anulação* ou *declaração de nulidade do casamento* (salvo em relação ao cônjuge de boa-fé, que pode, em se tratando de casamento putativo, optar por continuar usando o nome de casado); f) o *enteado pode requerer autorização judicial para usar o sobrenome do padrasto ou madrasta*, se estes concordarem (Lei n. 11.924/2009); g) para a inclusão de sobrenome de ascendentes, inclusive de avós.

6.2.2.6. Questões atuais relativas ao nome

Cabe, por razões de clareza, destacar com extrema brevidade algumas das questões atuais envolvendo o direito ao nome (lembrando que a questão da cirurgia de redesignação sexual e seus reflexos já foram mencionados).

6.2.2.6.1. O nome e a multiparentalidade

O STF, em 2016, decidiu ser possível a chamada multiparentalidade (STF, RE 898.060). Isso significa que uma pessoa pode ter, eventualmente, mais de um pai ou mais de uma mãe (poderá, digamos, ter um pai biológico e outro afetivo). O STF frisou ainda que essa constatação deverá produzir todos os "efeitos jurídicos próprios". Nesse contexto, havendo multiparentalidade judicialmente reconhecida, o filho poderá ostentar o nome de todos os pais, na medida em que mantém relação de parentesco (paterno-filial) com todos eles.

6.2.2.6.2. O nome social

O Decreto n. 8.727/2016 autorizou o uso do *nome social*, no âmbito da administração pública federal. Trata-se, segundo o parágrafo único do art. 1º do citado decreto, "da designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida". Sob o aspecto pragmático, significa que âmbito federal (pensemos em universidades federais, autarquias, empresas públicas, ministérios etc.) uma pessoa, agente público ou não, terá o direito de ser identificada pelo nome inerente à sua identidade de gênero. É o caso daqueles que, operados ou não, ainda não alteraram seus registros civis de nascimento.

Convém destacar, a propósito do tema, que em 2018 o Ministério da Educação – através do Conselho Nacional de Educação – editou a Resolução n. 1, de 19/01/2018, autorizando o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares. À luz da referida resolução, alunos maiores de 18 anos podem solicitar o uso do nome social durante a matrícula ou a qualquer momento sem a necessidade de representação ou assistência (a resolução fala em "mediação", no art. 3º). Já alunos menores de 18 anos

podem solicitar o uso do nome social durante a matrícula ou a qualquer momento, por meio de seus representantes legais, em conformidade com o disposto no artigo 1.690 do Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º da citada resolução).

6.3. Integridade intelectual

> *"Amigos, cada obra de arte devia trazer a seguinte advertência da censura: imprópria para os canalhas de todas as idades".*
>
> Nelson Rodrigues

Os direitos da personalidade na dimensão intelectual protegem o elemento criativo – tão próprio da inteligência humana. São as projeções da criatividade humana, como a liberdade de pensamento, o direito autoral e o direito ao invento. As criações artísticas e científicas encontram, aqui, seu resguardo jurídico[44]. Livros, quadros, canções, esculturas, toda a genialidade artística que a humanidade, século após século, criou, tem proteção neste espaço. Barbara Tuchman, respeitada historiadora, lembrou que o maior recurso, e a realização mais duradoura da humanidade, é a arte. Os direitos do autor possuem traços singulares, *sui generis*. São, a um só tempo, direitos da personalidade (criação intelectual derivada da liberdade intelectual) e, também, direito patrimonial (direito real à propriedade intelectual, direito oponível a todos, *erga omnes*). A obra criada é tutelada em razão de sua ligação com seu criador, mas é também tutelada em si mesma (tanto que os herdeiros não podem alterá-la, mesmo depois da morte do criador)[45]. O titular do direito autoral é o criador da obra, que pode ser pessoa natural ou jurídica (o titular pode ser até o Estado).

6.3.1. Direitos patrimoniais do autor

Destacamos acima que o direito autoral é um direito *sui generis*, possuindo natureza híbrida, mista. É que, a um só tempo, o direito de autor é direito da personalidade (pela ótica da criação intelectual, que decorre da inteligência humana) e, igualmente, é direito real sobre bem imaterial. Isto é: o direito autoral é *direito da personalidade*, no que tange à criação (ao invento), e é, também, *direito real* (a chamada propriedade intelectual, quanto ao seu exercício). Bipartem-se, pois, os direitos autorais em dois diferentes

[44] Pontes de Miranda, a propósito, lembra que "os nomes que se dão em ciência, como raios Röntgen, relatividade einsteiniana, moléstia de Chagas, teorema de Gödel, não entram no mundo jurídico. Participam da livre disponibilidade do espírito, que é essencial à ciência, e a carga de estabilidade, que tem o direito, prejudicaria o ambiente de liberdade de que devem desfrutar a investigação e a nomenclatura científica. A ciência mesma se protege (cf. MARTIN ISAAC, *Der Schutz des Namens*, 69; A. WEBER, *Dogmatik des Namensrecht*, 45)" (PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*. T. II. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p. 30).

[45] O *objeto* do direito autoral é a *criação*, seja uma obra literária, artística, científica, arquitetônica etc. Nesse passo, estão tuteladas as obras exteriorizadas pela palavra oral (uma conferência, palestra ou aula) ou escrita (um livro ou artigo científico), pelo gesto (mímica ou coreografia), por sinais ou traços identificadores (um mapa ou um desenho), pelos sons (uma melodia ou ópera), pela imagem (um filme ou novela), pelas figuras (uma obra arquitetônica ou escultura) ou mesmo pela combinação de diferentes meios de expressão (como uma obra teatral ou cinematográfica). Estão alcançados, inclusive, novas criações, descortinadas pelo gênio humano. Igualmente, são tutelados os direitos do tradutor e os direitos sobre a criação de programas de informática (o chamado *software*).

feixes, que estão, necessariamente, interligados, formando um todo, uno e indivisível: os direitos morais do autor (de essência personalíssima) e os direitos patrimoniais do autor (de índole material, produzindo efeitos na esfera dos direitos reais, por conta da caracterização de um modelo específico de propriedade). De outra sorte, têm natureza real, por conta do conteúdo patrimonial, o direito à exploração do direito autoral, bem como a prerrogativa de utilizar, fruir e dispor da obra (Lei n. 9.610/98, art. 28).

Em razão do caráter patrimonial dos *direitos materiais de autor* é admitida a sua transmissão por ato *inter vivos* ou *causa mortis*. Na transmissão em vida, a cessão é presumidamente onerosa e reconhece ao autor o direito irrenunciável à percepção de, no mínimo, 5% sobre o preço de comercialização da obra (Lei de Direitos Autorais, art. 38). É o exemplo do escritor que escreve um livro, cedendo a exploração a uma editora (o autor, caso queira, pode realizar uma cessão gratuita desses direitos patrimoniais). Na transmissão por morte, o direito autoral é transmitido pelo prazo de 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor (Lei de Direitos Autorais, art. 41). Findo esse período, a obra cai em domínio público. É o caso atualmente dos livros do genial Machado de Assis.

6.3.2. Direitos extrapatrimoniais do autor

> *"Penso no meu pai. Um artigo de Mário Rodrigues era lido, em voz alta, nos botecos mais analfabetos. E a pura delícia auditiva de sua prosa aumentava a tiragem do jornal em 30 mil exemplares ou mais. Era a época em que uma boa frase derrubava um ministério".*
>
> Nelson Rodrigues

Os direitos morais do autor são concebidos como direitos de personalidade a partir do século XIX[46]. Protege-se, através deles, a criação, e não os respectivos suportes que transmitem a criação (aliás, o registro da criação intelectual, no Brasil, é facultativo, não sendo constitutivo do direito do autor). Nesse sentido, quem escreve um livro é autor, mesmo sem o registro na Biblioteca Nacional. O autor pode modificar, a qualquer tempo, a sua obra. Pode até, se preferir, mantê-la inédita, não a divulgando (e responderá por danos morais – e eventualmente materiais – quem abusivamente a divulgue)[47]. Tem o direito moral de mantê-la livre de alterações feitas por terceiros (nem mesmo herdeiros poderão fazê-lo, embora possam atualizá-la, se houver autorização). Tudo isso diz respeito ao direito de paternidade da obra (por que não dizer, também, "direito de maternidade" da obra?). Nesse sentido, são de ordem personalíssima o direito à paternidade e o direito à nominação da obra, dentre outros (Lei n. 9.610/98, art. 24), por não trazerem consigo caráter econômico.

[46] STROMHLM, Stig. *Le droit moral de l'auteur*. Strockholm: Norstedt & Soners, 1967. Conferir ainda: ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito de autor e direitos conexos*. Coimbra: Coimbra, 1992; CHAVES, Antônio. *O criador da obra intelectual*. São Paulo: Ltr, 1995.

[47] Pode ainda reproduzir seus escritos mais de uma vez, em mais de um livro ou artigo (Pontes de Miranda, nosso maior jurista, fazia isso). Se no trecho já escrito o autor reputa que alcançou a concisão e a clareza possíveis, não há razão para – ao *voltar a abordar o tema*, em outra ocasião – não reproduzir o que ele mesmo escreveu antes.

Frisamos que o autor pode modificar, a qualquer tempo, sua obra. Pode até, se preferir, mantê-la inédita, não a divulgando e impedindo que terceiros indevidamente a divulguem. Não cabe, porém, medidas possessórias para proteger direitos autorais (STJ, Súmula 228: "É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral)". As tutelas específicas, tão louvadas pelo direito processual civil dos nossos dias, são bem-vindas na matéria – porque potencialmente eficientes nessas hipóteses.

Não há o chamado "plágio de ideias". Isto é, o que se protege é determinada obra, concluída e individualizada, não o caráter inefável e dinâmico das ideias. Aliás, muitos de nós pensamos ter tido uma ideia genial e inédita e descobrimos, depois, desolados, que alguém já a tivera muito antes de nós. Bem por isso, Robert Merton ironicamente escreveu: *"O plágio antecipado ocorre quando alguém rouba sua ideia original e a publica cem anos antes de seu nascimento"*.

6.3.3. Questões atuais relativas ao tema

O tema em análise nos convida, com frequência, a lançar o olhar para questões atuais, difíceis, complexas. Vejamos algumas delas.

6.3.3.1. Biografias não autorizadas

> *"Os mais fascinantes memorialistas são em geral pessoas que não têm muita coisa para contar."*
>
> Paulo Mendes Campos

Já tratamos, em outros livros, da questão das biografias não autorizadas. São possíveis? Em que medida? Como avaliar se retratam fielmente a vida do biografado ou estampam agressões? E ainda que retratem fielmente, ele, o biografado, não tem o direito de manter tais circunstâncias longe dos olhos do público? E as fotos? Se o direito de imagem, segundo tranquila jurisprudência, impede a publicação não autorizada de fotos, como compatibilizar tal proibição com as biografias, onde tais fotos são estampadas?

Neste livro, com o intuito da brevidade que nos move, convém lembrar que houve intenso debate na sociedade brasileira sobre a questão. As editoras, temendo processos, não mais publicavam biografias. Ruy Castro, talvez o mais conhecido biógrafo do Brasil, reclama: "Com isso se torna difícil escrever a história do Brasil". O próprio Ruy Castro teve problemas a esse respeito. Sua biografia de Garrincha – a Estrela Solitária – teve sua venda e reimpressão proibida durante 11 meses, em razão de uma ação proposta pela família do jogador[48]. A reação contra os livros

[48] Sérgio Cavalieri Filho – relator do agravo regimental contra a liminar no mandado de segurança que concedeu a busca e apreensão contra o livro – sustentou, a nosso ver sem razão, que "não se limitou o autor a relatar o futebol do Garrincha, a habilidade que o tornou um mito mundial, suas proezas nos gramados e vitórias nos campeonatos; infelizmente, foi muito além, invadindo a intimidade do cidadão Manoel dos Santos e apequenando a sua imagem. Se tal não bastasse, atenta o livro ainda agressivamente contra a intimidade do Garrincha, trazendo a público relato de fatos de sua mais restrita privacidade, desde a sua meninice até a sua morte. Seus dotes sexuais, seus vícios

parte, muitas vezes, de herdeiros[49]. Seria triste para o Brasil, culturalmente falando, que só pudéssemos ter, daqui em diante, biografias chapas brancas, mostrando o que interessa ao biografado, escondendo o que não convém mostrar. Há interesse social no conhecimento desses fatos.

O fato é que quem passou a vida inteira no noticiário – seja como político, cantor, jogador de futebol etc. – não pode pretender, de uma hora para outra, blindar sua imagem de qualquer abordagem, como se a pessoa em questão não tivesse feito, de algum modo, parte da história do país. Jurídica e culturalmente, isso não é possível. Nossa história, como nação, traz essas páginas, que não podem ser rasgadas. As biografias, ademais, são reconhecidas internacionalmente como uma forma de historiografia – uma forma, aliás, estabelecida e respeitável. Contam-se às centenas, ou mais que isso, as biografias existentes em certos países sobre determinadas figuras públicas. Sempre defendemos que a questão – seja legislativa, seja jurisprudencialmente – se resolveria no sentido da possibilidade da publicação das biografias sem a necessidade de autorização. Acreditamos, mesmo, que boa parte da polêmica foi juridicamente desnecessária. Já seria possível, e sem muita dificuldade, com a Constituição e a legislação hoje vigente, reconhecer que a publicação é possível e que a restrição prévia é inconstitucional.

Convém registrar, a propósito do tema, que o Plenário do STF, por unanimidade, julgando Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4815), afastou a exigência de prévia autorização para a publicação de biografias – no sentido, aliás, que sempre defendemos. A relatora, ministra Cármen Lúcia, conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, em harmonia com os direitos fundamentais à liberdade de expressão e de informação. A ministra, de modo enfático, registrou: "Em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento da pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas". O Código Civil, de fato, nos artigos citados, adotou posição nitidamente contrária à liberdade de expressão – em opção legislativa de constitucionalidade duvidosa, para dizer o mínimo[50]. Os abusos, portanto, devem ser objeto de reparação *a posteriori*

ocultos, seus casos amorosos, seus fracassos na cama, tudo é investigado, com microscópio e depois ampliado e divulgado sem retoques". O argumento do ilustre autor, com a devida licença, ao nosso ver peca duplamente: a) não se faz biografia apenas com glórias (mesmo porque nossas vidas *não são* feitas só de glórias); b) não se faz biografia sem vida pessoal. Biografia é, por definição, o percurso existencial de alguém, não só profissional, mas também pessoal.

[49] Triste e sintomático foi o caso recente do poeta Ledo Ivo. Pretendia publicar, num livro seu, uma foto de juventude em que estavam ele e Manoel Bandeira. Parentes distantes deste, no entanto, impediram a publicação, como impedem praticamente tudo a respeito de Bandeira. Outro livro censurado foi *Sinfonia de Minas Gerais: a vida e a literatura de Guimarães Rosa*. A filha do escritor, em entrevista, foi enfática: "Não existem biografias dele e não damos licença para ninguém. Muita gente quer fazer sensacionalismo, quer ganhar dinheiro à custa de gente famosa. Quem quiser saber de meu pai que leia o meu livro e está muito bom".

[50] Convém registrar que "em certos casos, será inegável a existência de interesse público no conhecimento dos fatos narrados, ainda que privados. Todos conhecem Einstein por suas grandes realizações, mas o contexto em que foram produzidas suas descobertas e os elementos que moldavam sua personalidade também podem ser classificados como informações de interesse público. Outro bom exemplo seria o de Hitler. Não por acaso, trata-se de uma das personalidades mais estudadas da história, inclusive sob perspectiva psicológica e psiquiátrica. Parece difícil

(sem excluir, por certo, outras formas além da indenização, como a publicação de ressalvas ou correções em novas edições). A verdade é que a experiência tem mostrado que as agressões, através de biografias, estão muito longe de serem a regra, sendo clara exceção (e, nesse último caso, abre-se espaço para o debate acerca da imposição de indenizações punitivas para coibir publicações ofensivas).

O STJ em 2018 afastou a indenização por danos morais pretendida por quem foi retratado (através de ator contratado para representá-lo) como coadjuvante em documentário que retratava a vida profissional de terceiro. Entendeu-se que os responsáveis pela direção da obra audiovisual tiveram o cuidado de retratar fato histórico da pessoa biografada. Frisou-se que a obra teve mais caráter histórico e de interesse social do que eventual finalidade comercial. Por fim, lembrou-se do julgamento do STF na ADI 4815, já citada (STJ, REsp 1.454.016). Em outro julgado (REsp 1.631.329), de modo semelhante, o STJ afirmou que a Súmula 403/STJ é inaplicável às hipóteses de divulgação de imagem vinculada a fato histórico de repercussão social (a Súmula 403 prevê que "independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais"). Atualmente, portanto, prevalece o entendimento do STF veiculado na ADI 4815.

6.3.3.2. *Hate speech*

> *"Um fanático é alguém que não pode mudar de opinião e não quer mudar de assunto".*
>
> Winston Churchill

Hate speech, ou discurso do ódio, é a expressão – oral, escrita ou por sinais – contra determinado grupo religioso, étnico, regional etc. É um tema que já nasce envolvo em dificuldades, uma vez que – como tantos outros no mundo contemporâneo – tem início a partir do exercício de um direito fundamental: a liberdade de expressão. Até onde vai, ou pode ir, o seu exercício? Em outras palavras, devemos tolerar os intolerantes? Devemos aceitar quem não aceita os outros? As democracias constitucionais contemporâneas estão prontas para aceitar manifestações ódio e intolerância como partes da liberdade de expressão?[51]

imaginar que algum dado de sua vida – por mais íntimo que seja – possa ser tido como indiferente ao interesse público" (STF, ADIn 4.815, trecho do voto do min. Luis Roberto Barroso).

[51] A questão traduz uma pergunta incômoda: devemos ser tolerantes com os intolerantes? Devemos dar liberdade às ideias que odiamos? Argumenta-se que "nem todo aspecto da diversidade cultural é digno de respeito. Algumas diferenças – o racismo e o antissemitismo são exemplos óbvios – não merecem respeito, ainda que se deva tolerar certas expressões das opiniões racistas e antissemitas" (GUTMANN, Amy. In: TAYLOR, Charles. *El multiculturalismo y "La Política del Reconocimiento"*. Introdução de Amy Gutmann. Comentarios de Susan Wolf, Steven C. Rockefeller, Michael Walzer; ensayos de Jürgen Habermas, K.Anthony Appiah. Trad. Mónica Utrilla de Neira; Liliana Andrade Llanas y Gerard Vilar Roca. México: Fondo de Cultura Económica, 2009, introdução, p. 49). Aliás, podemos falar em obrigatoriedade do reconhecimento das diferenças. É o que conclui, a partir da ideia de tolerância, Michael Walzer (WALZER, Michael. *Da Tolerância*. Trad. Almiro Pisetta. São Paulo: Martins Fontes, 1999). O autor lembra que a tolerância da diferença é intrínseca à política democrática. Importante registrar que Walze, em geral, em sua obra, não utiliza o termo "pluralismo" para se referir à diversidade de concepções individuais sobre os melhores caminhos a

Algo é certo (e já frisamos): a Constituição garante a liberdade de expressão não só para ideias majoritárias, mas também minoritárias. Não só para ideias progressistas, mas também conservadoras (sem falar que a categorização do que é conservador ou progressista é bastante relativa). Por outro lado, não há direito ilimitado, todos são socialmente condicionados. O STF, de modo semelhante, ponderou que "a liberdade de expressão não deve proteger somente ideias positivas, socialmente aceitas, inofensivas e neutras, mas também aquelas negativas, ofensivas, incômodas e chocantes. Essa é uma exigência do pluralismo e da tolerância, essencial em uma sociedade democrática (STF, ADIn 4.815, voto do min. Luis Roberto Barroso). Essa é a regra amplamente geral e aceita. Mas mesmo aqui há limites.

O STF – sob o ângulo penal, que não é o deste livro – analisou, em 2003, uma situação emblemática: o caso Ellwanger. Julgou-se na ocasião *habeas corpus* que buscava, como pano de fundo, discutir os livros editados pelo paciente, que negavam o holocausto e defendiam o antissemitismo. O STF, por maioria (7 x 3), manteve a condenação por crime de racismo. O tema mostra – mais uma vez e com nitidez – que não há campos jurídicos absolutos, por mais respeitável que seja o direito a ser exercido. Não há, nesse sentido, primazia incontrastável da liberdade de expressão. O STF afirmou que "o preceito fundamental da liberdade de expressão não consagra o direito à incitação do racismo". Se alguém, ao exercê-la, agride outrem (ou um grupo étnico, por exemplo), a indenização por dano moral será a resposta devida (ou uma das respostas). Cremos, como temos tantas vezes frisado, que deve-se evitar, mesmo nesses casos, a censura prévia – por abrir precedentes perigosos em relação aos quais nem sempre é possível a volta. Somos livres para pensar e para expressar, como bem nos aprouver, nossos pensamentos, sentimentos e impressões. Quem, porém, prefere usar esse direito de modo virulentamente agressivo, deverá saber que é responsável civilmente pelo que diz, e que havendo dano, responderá por ele.

Em outra oportunidade, o ministro Celso de Melo, ao votar na ADI 4815, consignou que a garantia fundamental da liberdade de expressão é um direito contramajoritário, isto é, o fato de uma ideia ser tida como errada por pessoas, grupos ou governos não é argumento bastante para que sua veiculação seja condicionada à prévia autorização. Ressaltou, porém, que a incitação ao ódio contra qualquer pessoa, grupo social ou confessional não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão.

Em determinado caso, a justiça condenou pastor evangélico que, durante festa religiosa de embanda, infiltrou-se dentre os umbandistas, vestindo-se de branco para distribuir panfletos evangélicos que ridicularizavam o negavam as divindades dos umbandistas. Nos panfletos, que buscavam atrair fiéis para a igreja evangélica, a divindade Iemanjá é comparada ao saci-pererê e ao curupira. A liberdade de religião (e a liberdade de expressão) não autoriza que a exerçamos ridicularizando outros cultos, ou agindo para diminui-los de modo agressivo.

seguir (que estaria ligada à autodeterminação individual), mas – em concepção comunitarista – para descrever a pluralidade de identidades culturais, em específicos contextos históricos.

7. A OPÇÃO PRIORITÁRIA PELA TUTELA PREVENTIVA

As violações aos direitos da personalidade acarretam sanções múltiplas[52]. As tutelas específicas são muito importantes nessa matéria. As tutelas podem englobar deveres negativos e positivos (um não fazer e um fazer). Além, é claro, da indenização compensatória em razão dano extrapatrimonial, para os casos em que o dano já ocorreu. Não se exige culpa para que as lesões a direitos da personalidade recebam sanções civis. O dano, ademais, é presumido, pela simples violação ao bem jurídico tutelado (STJ, REsp 506.437). A tutela mais adequada para os direitos da personalidade (bens extrapatrimoniais) não é a tutela repressiva, mas a tutela preventiva. Nesse contexto, "os direitos não patrimoniais devem ser tutelados sempre na forma preventiva, sob pena de o direito em si ser transformado em direito à indenização"[53].

A tutela preventiva é uma realidade característica do direito civil atual. Sua existência independe da legislação infraconstitucional, sendo diretamente inferida da Constituição, embora, conforme veremos, o Código Civil a ela não foi indiferente, tendo previsto, em dois artigos específicos, a tutela inibitória no sistema do direito civil. O art. 12 do Código Civil tem a seguinte dicção normativa: "Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei". Consagra esse artigo, de modo inequívoco, a tutela inibitória, cuja nota específica consiste em buscar prevenir a lesão, ou a ameaça de lesão a direito, nos exatos termos do art. 5º da Constituição Federal de 1988.

A dignidade humana impõe ao Estado – embora não só a ele – o dever de agir, adotando as providências minimamente necessárias à salvaguarda da vida humana, sendo ilícita a omissão. Nessa trilha, o Judiciário, concretizando o princípio, há de fazê-lo real, impondo aos poderes, públicos ou privados, a adoção de reais providências, máxime preventivas, com o propósito de impedir, ou fazer cessar, as lesões a tais direitos[54].

A tendência do processo civil atual é valorizar a tutela específica, ou seja, buscar soluções que se aproximem, tanto quanto possível, do resultado buscado pelo direito material. Direito civil e direito processual civil, nesse contexto, dialogam mais do que nunca, buscando meios e formas de conferir resultados – reais e úteis – às demandas. A propósito, o CPC/2015, de modo correto, encarou o ilícito civil de modo amplo, prevendo que "para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência

[52] Cabe lembrar que "a tutela dos direitos fundamentais nas relações privadas não se esgota na garantia de uma obrigação geral de abstenção, nem na reparação dos danos pelas lesões perpetradas, através da responsabilidade civil. A proteção conferida pela ordem constitucional é mais ampla, e envolve tanto uma tutela preventiva dos direitos como uma atuação repressiva e corretiva. Ademais, ela pode abranger tanto obrigações negativas do particular, como deveres positivos, dependendo das circunstâncias de cada caso e da concreta configuração dos interesses em jogo" (SARMENTO, Daniel. *Direitos Fundamentais e Relações Privadas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 301).

[53] MARINONI, Luiz Guilherme. *Novas Linhas do Processo Civil*. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 55

[54] Em caso de leucemia gravíssima em criança recém-nascida, impondo o urgente transplante de medula óssea, os pais foram aconselhados a fazer a cirurgia no exterior, tendo a União sustentado que, naquele momento, a concessão desse tipo de auxílio estaria suspensa. Afirmou, então, o Tribunal: "Admitir sustar todo o custeio desses tratamentos excepcionais e urgentes é negar o direito fundamental à saúde e à vida, sentenciando o paciente à morte". Afirmou, ainda, o STJ que "defronte de direito fundamental, cai por terra qualquer outra justificativa de natureza técnica ou burocrática" (STJ, REsp. 338.373).

agora buscar esquemas mais operacionais, definindo certos âmbitos de proteção[58]. Haveria nesse sentido, lá, uma retração da cláusula geral da personalidade em favor em esquemas dotados de maior especificidade.

7.3. A tutela (atual) da personalidade: indo além da tutela ressarcitória

A resposta negativa claramente se impõe. A tutela da personalidade é uma tutela ampla, não exaustiva, que se realiza mediante cláusula geral generosa o suficiente para se adaptar às inúmeras situações existenciais que a realidade – iconoclasticamente – apresenta. Não se trata, portanto, apenas de indenização. A indenização (por dano moral, por exemplo) é uma tutela possível, mas nem sempre será a mais adequada. Gustavo Tepedino frisou a insuficiência de "qualquer construção doutrinária que, tipificando vários direitos da personalidade, ou cogitando de um único direito geral da personalidade, acaba por limitar a proteção da pessoa à atribuição de poder para salvaguarda meramente *ressarcitória*, seguindo a lógica dos direitos patrimoniais"[59]. A propósito, Barbosa Moreira, com finura, percebeu que as possibilidades de tutela preventiva, no campo do direito privado, cingiam-se à proteção de coisas, e não dos direitos da personalidade. Assim é que existem, para litígios entre particulares, apenas o interdito proibitório e a nunciação de obra nova, remédios que protegem a posse e a propriedade[60].

Como exemplo de tutela não ressarcitória podemos citar os chamados *mandados de distanciamento* ou *ordem de restrição de aproximação*. O instituto – que o art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) denominou de "medidas protetivas de urgência" – ganhou destaque e utilidade em nosso ordenamento jurídico. Tem sido usado com frequência. Aliás, os jornais noticiam, semana após semana, casos de homens que matam ex-mulheres e filhos e depois se suicidam. Casos dramáticos e tristes. Em situações assim, com um quadro fático de agressões e ameaças, poderá ser imposta a *ordem de restrição de aproximação* ou *mandado de distanciamento*. Nesse caso, a liberdade de locomoção de alguém encontra limite no direito à vida e à integridade física de outra pessoa.

8. QUAIS AS (REAIS) CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE?

São raros os consensos nos debates jurídicos de nossos dias. Não é diferente no que se refere às características dos direitos de personalidade. Quais são essas características? Elas são absolutas ou relativas? Isto é, a indisponibilidade, por exemplo, que

[58] Cf. CORDEIRO, Antônio Menezes. *Tratado de Direito Civil Português: parte geral, coisas.* Coimbra: Almedina, 2004, t. 3, p. 48.

[59] TEPEDINO, Gustavo. A crise de fontes normativas e a técnica legislativa na parte geral do Código Civil de 2002. *Revista Forense.* Vol. 364, Rio de Janeiro, 2002. (novembro/dezembro), pp. 113/123, p. 117. A tutela inibitória, e os demais mecanismos de tutela específica, sendo de cognição exauriente, dispensam eventual ação de reparação de danos. Destina-se a tutela inibitória à resolução definitiva da controvérsia, gerando coisa julgada material, como meio próprio e autônomo para excluir a ameaça da ocorrência do ilícito. Ver: MARINONI, Luiz Guilherme. *Tutela inibitória (individual e coletiva).* São Paulo: RT, 2000; ARENHART, Sérgio Cruz. *A tutela inibitória da vida privada.* São Paulo: RT, 2000. De todo modo, as tutelas preventivas e repressivas podem, em determinados casos, coexistir.

[60] BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tutela sancionatória e tutela preventiva. *Temas de direito processual, segunda série.* São Paulo: Saraiva, 1996, p. 26.

se aponta como sendo uma delas, é absoluta ou pode ser relativizada? Se afirmativa a resposta, outra pergunta se põe: relativizamos apenas o exercício ou a própria titularidade do direito?

São questões, como se vê, complexas, e bastante atuais. O STJ já teve oportunidade de decidir que "os direitos da personalidade são inalienáveis, vitalícios, intransmissíveis, extrapatrimoniais, irrenunciáveis, imprescritíveis e oponíveis *erga omnes*" (STJ, REsp 807.849, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJ 06/08/2010). Alguns acrescentam ainda que são inatos, preexistem à ordem jurídica. Outros preferem dizer que eles são uma construção histórica. A rigor, essas duas visões nem se opõem tanto quanto se pensa, porque hoje esses direitos são oponíveis a qualquer nova ordem jurídica – seja como algo inerente ao ser humano, seja como construção histórica.

O primeiro ponto que convém frisar, em relação a eles, é que estamos diante de direitos extrapatrimoniais. Por extrapatrimoniais deve-se entender direitos e interesses existenciais, direitos e interesses cujo conteúdo precípuo não é o patrimônio, e sim a bela e rica complexidade espiritual, física, intelectual e moral do ser humano. É disso que estamos falando, ao falar sobre os direitos da personalidade[61]. São direitos que não podem ser alienados ou penhorados (característica da inalienabilidade e da impenhorabilidade) nem transmitidos a outrem (característica da intransmissibilidade). O STJ, a propósito, já reconheceu que "os direitos da personalidade, de que o direito à imagem é um deles, guardam como principal característica a sua intransmissibilidade" (REsp 268.660). Nem muito menos seria possível que houvesse renúncia válida em relação a eles (característica da indisponibilidade)[62]. A indisponibilidade não impede, como vimos, que determinados aspectos (a imagem, por exemplo), sejam objeto de negócios jurídicos. A análise deve ser feita de modo contextualizado e de acordo com as cláusulas constitucionais e legais. Um contrato, por exemplo, cujas prestações envolvessem deveres sexuais, não seria válido. Não se trata de bem jurídico que possa ser comercializado de modo válido, ou que possa ser tido como algo renunciável ou disponível negocialmente. Em outras palavras, as prestações não são exigíveis.

O Código Civil estabelece no art. 11: "Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária". Trata-se de regra pouco feliz. Podemos destacar que: a) a menção às exceções legais é inútil (para que a lei posterior traga novas disposições não é preciso que a lei anterior permita); b) a menção às características dos direitos da personalidade não é tarefa legal e, além do mais, foi claramente incompleta; c) há, sim, disponibilidade relativa do exercício. Aliás, é importante, nesse tema, distinguir titularidade e exercício. Eu não posso renunciar à minha imagem,

[61] Aliás, mesmo a característica da extrapatrimonialidade dos direitos da personalidade deve ser encarada como relativa, e não absoluta (ou encarada em relação ao exercício, e não à titularidade). Afinal, há, sem dúvida, aspectos patrimoniais nesses direitos. Pensemos nos inúmeros negócios jurídicos que são feitos – e ninguém lhes nega a validade – a respeito de uso de imagem ou nome, com fins comerciais. O ator que cede o uso de sua imagem para determinada faculdade privada em outdoors, por exemplo, não perde a titularidade do direito, mas fica obrigado a aceitar que outrem o utilize, no modo e na forma ajustados.

[62] Conferir STANCIOLI, Brunello. *Renúncia ao exercício de direitos da personalidade.* Belo Horizonte: Del Rey, 2010. Desse modo, embora os direitos de personalidade sejam indisponíveis ao seu titular, admite-se, eventualmente, cessão em seu exercício, em certas situações e dentro de certos limites. Significa a possibilidade de ato de disposição, em caráter relativo (não permanente nem geral), e desde que não viole a dignidade de seu titular.

à minha honra. Mas posso dispor, contratualmente, de modo válido, sobre minha imagem. Essa disposição dirá respeito ao exercício (algumas pessoas vão além: expõem suas vidas de modo quase integral no *youtube*, por exemplo). Em relação ao exercício, é fundamental que saibamos que há flexibilizações e maior tolerância da doutrina e jurisprudência. Essas disposições (ou flexibilizações), no entanto, além de razoáveis, devem ser voluntárias e temporárias.

São, outrossim, direitos que não toleram que ocorra, em relação a eles, a prescrição (isto é, o não exercício, por determinado tempo, não implica em prescrição da respectiva pretensão). Aqui é necessário que tenhamos certa atenção. Dizer que são imprescritíveis significa dizer que a qualquer tempo, antes da morte, poderão ser exercidos. Não significa, no entanto, que os aspectos patrimoniais decorrentes de lesões a direitos da personalidade não prescrevam. As pretensões relativas aos danos morais, no Brasil, prescrevem (em regra) em três anos, na forma do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Se a pretensão se origina de acidente de consumo, a prescrição ocorre em cinco anos (CDC, art. 27).

São direitos vitalícios. Acompanham a vida humana enquanto ela existir, só se extinguindo com a morte do corpo físico. É possível, ainda depois da morte, que existam as chamadas lesões indiretas, reflexas ou por ricochete. Se, por exemplo, um livro ou uma reportagem ataca a honra de alguém já falecido, os filhos podem ingressar com ação de dano moral contra a editora ou o jornal. Nesse caso, porém, o farão em nome próprio (não haverá, aí, a chamada legitimação extraordinária ou substituição processual). Nesse caso, os parentes – ou mesmo o cônjuge ou companheiro – defendem direito próprio. Os reflexos buscados são patrimoniais. O espólio, porém, "não tem legitimidade para buscar a reparação por danos morais decorrentes de ofensa *post mortem* à imagem e à memória de pessoa" (STJ, REsp 1.209.474).

Podemos dizer, ainda, que são absolutos. Não absolutos no sentido de direitos socialmente incondicionados (algo que atualmente não existe), mas absolutos no sentido que a doutrina costumava usar no início – e em meados – do século passado, absolutos no sentido de que são direitos oponíveis a todos (*erga omnes*)[63]. São, ainda, contínuos, isto é, acompanham a pessoa enquanto ela viver (característica da vitaliciedade). Poderíamos também lembrar a preeminência (característica da preeminência). São direitos preeminentes no sentido de sua singular importância. Em outras palavras, do que valeria o direito de crédito, de propriedade, se não houvesse o direito à integridade física, à honra, ao nome?

8.1. A dupla inerência dos direitos da personalidade

Podemos falar, em relação aos direitos da personalidade, de "dupla inerência". Os direitos da personalidade são "as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim seus prolongamentos e projeções"[64].

[63] Pontes de Miranda, por exemplo, lembrou que "o direito de personalidade de A é tanto direito perante B quanto perante mim e perante todos os que têm de atender a que A é pessoa" (PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*. T. I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p. 129).

[64] FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da Personalidade. *Revista dos Tribunais*, n. 567, p. 9, jan. 1983.

Menezes Cordeiro, a propósito da *dupla inerência*, lembrava que esses direitos têm uma dupla e indissociável ligação ao seu titular e ao seu objeto. A pessoa, lembremos, não é objeto das relações jurídicas. Ela é sujeito das relações jurídicas. Porém, nos direitos da personalidade, aspectos da pessoa passam a ser *também* objeto da relação jurídica. É nesse sentido que se pode falar em "dupla inerência". Porque esses direitos estão não só estão ligados a alguém, como sujeito da relação, mas estão também ligados ao objeto da relação (honra, partes do corpo etc.). Nesse sentido, aliás, é que podemos dizer que os humanos possuem direitos da personalidade sobre o próprio corpo (aspecto físico da personalidade), por exemplo.

Vejamos, a seguir, da transmissão dos efeitos patrimoniais das lesões personalíssimas.

8.2. A transmissão dos efeitos patrimoniais das lesões personalíssimas e a questão da prescrição

É verdade, e parece não haver dúvidas sobre o ponto, que os direitos da personalidade – justamente por dizerem respeito aos direitos e interesses existenciais dos seres humanos – trazem a nota da intransmissibilidade. Hoje, porém, se sabe que isso não significa que as repercussões patrimoniais desses direitos não possam ser transmitidas a outrem: podem. O direito à indenização, nesse sentido, é transmissível. Mesmo que a lesão tenha atingido um direito da personalidade, um direito ou um interesse existencial.

Podemos falar em prescrição em relação às questões personalíssimas? Devemos, aqui, segundo cremos, distinguir se estamos falando dos efeitos patrimoniais das lesões ou das lesões em si mesmas. O que não prescreve é a pretensão em si mesma. Digamos que um marido subjuga, fisicamente, a esposa por décadas. Mesmo sem ter exercido as ações para resguardar sua integridade física, ela poderá fazê-lo sempre que quiser. Inexistem, por óbvio, prescrições em situações semelhantes. Sempre que a pretensão não tiver, em si mesma, natureza pecuniária, não haverá prescrição.

As pretensões relativas ao dano moral, porém, em regra prescrevem – nos prazos e na forma que a lei determinar[65]. Poderá haver prescrição, por exemplo, que seja regulada pela regra geral de três anos prevista no Código Civil (artigo 206, § 3º, V), ou poderá haver prescrição regida pela regra de cinco anos prevista no CDC (art. 27). No primeiro caso, por exemplo, quando houver um acidente de carro com vítimas fatais (danos morais aos familiares e, eventualmente, também materiais). No segundo caso – cinco anos –, quando, por exemplo, as mortes resultarem de desastre aéreo em voo comercial (TAM, GOL, AZUL etc). Mesmo que as vítimas, no caso, não sejam passageiros (serão ainda assim consumidores por equiparação, *bystanders* – por exemplo: vítimas que se encontravam no solo e foram atingidas pela queda do avião, em sua pessoa ou seus bens).

[65] Uma exceção a essa afirmação temos nos danos civis resultantes de torturas no período militar. A jurisprudência, a propósito, firmou a tese da imprescritibilidade. Conferir, por exemplo, dentre muitos outros, o REsp 1.027.652.

9. DIREITOS DA PERSONALIDADE E DANOS MORAIS: REFAZENDO O PERCURSO HISTÓRICO-JURISPRUDENCIAL

Os danos morais não são a *tutela ótima* para os direitos da personalidade. A *tutela ótima* será preventiva, na modalidade inibitória. Muitas vezes, porém, o dano não pode ser – ou não foi – evitado. O dano já ocorreu. Nada mais se pode fazer quanto a isso. Nessas situações, que não são raras (pelo contrário, são a regra), a compensação moral há de ser fazer presente. Lembremos que o dano moral tem assento na Constituição da República. A Constituição a ele se refere no art. 5º, incisos V ("é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem") e X ("são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação").

Também existem referências no plano da legislação infraconstitucional. O CDC, no art. 6º, VI ("São direitos básicos do consumidor: a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos"). O Código Civil, no art. 186 ("Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"). Não existe, no Brasil, conceito legal de dano moral. Alguns projetos de lei, em tramitação no Congresso Nacional, buscam defini-lo, nem sempre com felicidade. Cabe, aliás, lembrar o sábio brocardo romano (*omnias definitio periculosa est*). O legislador, em princípio, não deve se ocupar com as definições, deixando-as à doutrina.

O Supremo Tribunal Federal, até meados dos anos sessenta, dizia, de modo peremptório, que "não é admissível que os sofrimentos morais deem lugar à reparação pecuniária, se deles não decorre nenhum dano material" (STF, RE 11.786, Rel. Min. Hahnemann Guimarães, 2ª T., DJ 06/10/52). Ou seja, não se indenizava, no Brasil, os danos morais; apenas os danos materiais seriam indenizáveis[66]. Caminhou-se, depois, para aceitar sua indenização, desde que acompanhado de um dano material. Contudo, certos julgados, ainda antes da Constituição de 1988, admitiam o dano moral puro (desacompanhado de um dano material), mas no cálculo da indenização se revelava, claramente, que se estava indenizando prejuízos materiais, e não morais.

Isto é, o que se estava indenizando, na verdade, não era a dor da perda dos filhos, mas os gastos materiais para a criação deles até a data da morte. Uma indenização claramente material, travestida de indenização por dano moral: "Morte de menor que caiu do trem onde viajava. Na indenização concedida aos pais, pelo prejuízo presumível decorrente da morte do filho melhor, está incluído o ressarcimento de

[66] Convém repetir. Há algumas décadas, no Brasil, o dano moral não era indenizável. A jurisprudência refletia essa lamentável visão: "Responsabilidade civil. Falha na vigilância hospitalar. Dano moral. Não é ressarcível, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal" (STF, RE 86.548, Rel. Min. Leitão de Abreu, 2ª T, DJ 03/07/79). A perda de um ente querido, nessa linha de ideias, não perfaria dano moral: "Discussão a respeito de ser indenizável o dano moral sofrido pelo pai de quem foi vitimado em acidente ferroviário. O direito positivo brasileiro só permite a indenização pelo dano moral à pessoa mesma que haja sofrido lesão corpórea deformante, e não a seus pais ou a seus familiares. Portanto, no caso de morte não é indenizável o dano moral" (STF, RE 83.978, Rel. Min. Antônio Neder, 1ª T, DJ 01/07/80).

dano moral resultante do mesmo fato" (STF, RE 85.127, Rel. Min. Soares Munoz, 1ª T, DJ 19/04/79). Tal julgado bem traduzia a opção valorativa então prevalente, de submeter a pessoa ao patrimônio.

Passados alguns anos chegou-se à Súmula 491 do STF, que estabeleceu ser indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça atividade remunerada. Estabeleceu-se, através dela, que a morte dos filhos menores, que não trabalham, é indenizável (Súmula 491/STF: "É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado"). Com essa Súmula, passou-se a incluir, nas verbas indenizatórias, não apenas os gastos passados, mas também os presumíveis ganhos futuros frustrados.

Porém até o advento da Constituição Federal de 1988 havia julgados, e não eram poucos, que simplesmente negavam indenização ao dano moral. Com a Constituição da República, que previu explicitamente a reparação do dano moral no artigo 5º, incisos V e X, acabaram os espaços para as recusas hesitantes. A perda de um ente querido gera, portanto, sem dúvida, dano moral, que aliás, segundo a jurisprudência atual do STJ, cujo sofrimento nem precisa ser provado, é presumo (dano *in re ipsa*)[67]. Aliás, convém frisar que a trajetória do instituto do dano moral e dos direitos da personalidade andaram juntas durante boa parte da caminhada histórica no século passado – e juntas, também, enfrentaram forte resistência da doutrina e jurisprudência brasileiras.

10. DEVERES DE PROTEÇÃO POR PARTE DO ESTADO

O Estado, tradicionalmente, foi encarado como um inimigo dos direitos fundamentais. Esses direitos foram forjados, inicialmente, como direitos contra o Estado, oponíveis a ele. O Estado deveria se abster, deveria não lesar. Hoje, porém, a reflexão contextualizada nos recomenda ir além. No contexto de constituições normativas e vinculantes progressivamente se fortalecem os *deveres estatais de proteção*. Dever de proteger os cidadãos e de impedir lesões a direitos fundamentais. Sendo óbvio que a vida, a integridade física, a honra, a liberdade, a privacidade são ameaçadas, de modo constante, por particulares, o Estado é quem pode impedir essas violações. Aparece, nesse sentido, como amigo dos direitos fundamentais.

É comum que chamemos de clássica a função negativa dos direitos fundamentais, no sentido de evitar que o Estado os infrinja (*Abwehrrecht*)[68]. Hoje, porém, já avançamos consideravelmente em relação à essa posição, e ela já não nos satisfaria.

[67] Assim, no contexto descrito, "o deferimento da indenização pelo dano moral sofrido com a morte do marido e pai dos autores independe de prova do efetivo sofrimento, que decorre da natureza das coisas" (STJ, REsp. 153.155). O STJ destacou que "o dano moral, tido como lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às vezes de difícil constatação, por atingir os seus reflexos parte muito íntima do indivíduo – o seu interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação que o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral humano" (STJ, REsp. 121.757). Como pondera Ruy Rosado de Aguiar: "É certo que na fixação da indenização pelo dano moral haverá de ser contemplada a situação da vítima, o sexo e o seu projeto de vida)" (STJ, REsp. 251.395).

[68] Podemos dizer que na *dimensão subjetiva*, os direitos fundamentais são direitos do cidadão contra o Estado. Já na *dimensão objetiva* compreendem uma ordem de valores que permeia e fundamenta a ordem jurídica em suas opções valorativas básicas. Em relação aos direitos da personalidade, podemos conceituá-los "como projeção de

Essa teoria clássica, por assim dizer, não descreve o que acontece atualmente na prática constitucional, seja europeia, seja brasileira. O reconhecimento de uma dimensão positiva dos direitos fundamentais significa que o Estado não deve apenas respeitá-los, mas também protegê-los (*Schutzpflicht des Staats*).

Não basta, portanto, uma postura de abstenção estatal, no sentido – hoje insuficiente – de não causar danos. Isso ficou no passado, no museu das ideias. Hoje é imprescindível que o Estado assuma uma postura ativa no sentido de resguardar os cidadãos de agressões de terceiros (desde o clássico caso *Lüth, leadind case* julgado pela Corte Constitucional Alemã em 1958, discute-se a questão da aplicação horizontal dos direitos fundamentais. Essa influência não é limitada ao direito público, mas alcança todos os campos do direito, incluindo o civil). Cabe frisar que o agente público, hoje, está obrigado a sacrificar o mínimo de direitos fundamentais, para preservá-los ao máximo[69]. Dieter Grimm, desenvolvendo a questão, pontua: "Na Alemanha, a Corte Constitucional pode declarar uma lei nula não apenas quando o legislador tenha ido longe demais na limitação a um direito fundamental, mas também quando tenha feito muito pouco no sentido de protegê-lo contra ofensas provocadas por agentes privados"[70].

Vivemos – em relação à responsabilidade civil do Estado – uma nova fase (em relação às três fases históricas, usualmente apontadas), que é o Estado como garantidor dos direitos fundamentais. A diferença entre a terceira e a quarta fase é clara: na terceira – a chamada fase objetiva ou publicista – o Estado responde, sem culpa, se lesionar um cidadão. Na quarta *e atual* fase, o Estado responde, sem culpa, *se não proteger adequadamente* um cidadão[71]. Mantém-se, por certo, o já conquistado nas fases anteriores, mas se dá um passo além. Há um dever qualificado de proteção, que se corporifica concretamente, não de modo abstrato. Esse dever de proteção não diferencia as funções do Estado – o dano pode ocorrer em qualquer uma delas.

A função protetiva obriga o Estado a agir. A agir de modo proporcional e eficiente (ambos princípios com sede constitucional), na proteção da vida, dignidade, saúde, segurança dos cidadãos. É o princípio da proteção, aplicado à responsabilidade civil do Estado – o que configura, pensamos, a quarta fase ou geração, consubstanciada no Estado como garantidor dos direitos fundamentais (naturalmente, tais fases – na

algum aspecto da personalidade em espaços de subjetividade e intersubjetividade, que deve ser tutelado pelo Estado na medida da necessidade individual, de acordo com os valores que a própria pessoa estabeleceu como prioritários para o livre desenvolvimento da sua personalidade". TEIXEIRA, Ana Carolina. Aspectos gerais dos direitos da personalidade. In: TEIXEIRA, Ana Carolina; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite (Coords). *Manual de Teoria Geral do Direito Civil*. Belo Horizonte: Del Rey, 2011, pp. 229-248, p. 232.

69 FREITAS, Juarez. *Responsabilidade civil do Estado*. (Org.). São Paulo: Malheiros, 2009, p. 174.

70 GRIMM, Dieter. A função protetiva do Estado. Trad. Eduardo Mendonça. In: *A Constitucionalização do Direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas*. Cláudio Pereira de Souza e Daniel Sarmento (Orgs). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 160. Cabe lembrar que Dieter Grimm foi juiz do Tribunal Constitucional Federal Alemão, tendo vivenciado muitas das transformações teóricas que narra.

71 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. *Manual da Responsabilidade Civil do Estado à luz da jurisprudência do STF, do STJ e a Teoria dos Direitos Fundamentais*. 4ª edição. Salvador: Juspodivm, 2017. Busca-se, assim, garantir o cumprimento do dever estatal de tutela. O STF já teve oportunidade de afirmar que os "direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote)". Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam "não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote)" (STF, HC 104.410).

verdade, qualquer abordagem histórica – são esquemáticas e aproximativas, não sendo razoável buscar, por meio delas, uma precisão absoluta nas sempre superpostas experiências sociais).

11. OUTRAS QUESTÕES POLÊMICAS

> *"E você, gosta de carnaval? – foi a pergunta, despretensiosa e singela, que ela me fez. Se eu gosto de carnaval. A resposta podia ser qualquer uma – gosto, odeio, adoro, mais ou menos, a cada três anos, ou só em Veneza – ela, acho, não ia se importar. Aliás, isso é próprio de certas pessoas. Perguntam com tanto interesse pela resposta como por mecânica quântica. Mas a pergunta ficou, cá dentro, ecoando. Eu gosto de carnaval? Eis uma questão que merecia tratados, teses, encontros. Gostar de carnaval não é coisa simples, como gostar de caruru, de sorvete de pinha, dessas coisas que ou se adora ou se odeia".*
>
> Felipe Braga Netto

Mencionaremos aqui, com muita brevidade, outras questões polêmicas que podem ser de interesse para o leitor (embora sabendo que praticamente *tudo*, nesta matéria, traz as cores vivas da controvérsia). Podemos por exemplo indagar: personalidade é direito ou é a possibilidade de ter direitos? A respeito da pergunta acima, articula-se: "Há controvérsia na doutrina acerca da natureza jurídica dos direitos de personalidade. Uma corrente minoritária nega a existência deles, argumentando que constituem meros reflexos da proteção assegurada pelo direito objetivo. Outra corrente, bem mais expressiva e atualmente dominante, identifica-os aos direitos subjetivos. Existem, ainda, aqueles que os consideram como direitos subjetivo *sui generis*"[72].

Pontes de Miranda esclarece que os que negam que a personalidade seja direito subjetivo partem de visão puramente privatística dos direitos subjetivos. Argumenta ainda que nega-se a qualidade de direito à personalidade apenas porque trata-se de direito notório e ninguém, hoje, sem escândalo, negaria às pessoas esses direitos[73]. Observe-se que ele escrevia em meados do século passado. Há, ainda, quem – como Pietro Perlingieri – afirme que cuida-se não de direitos subjetivos, mas de situações subjetivas. Que a categoria dos direitos subjetivos seria mais própria do *ter*, ao passo que os direitos da personalidade operam com o *ser*[74]. As situações jurídicas existenciais, segundo o autor,

72 GOMES, José Jairo. *Teoria Geral do Direito Civil*. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 94. A grande maioria da doutrina considera os direitos da personalidade como direitos subjetivos (é também essa a nossa posição, que aliás já defendemos em outra oportunidade: FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. *Curso de Direito Civil*. v. 1. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 203). Paulo Lôbo teoriza: "Os direitos da personalidade são direitos subjetivos, mas sem a restrição histórica que estes tiveram, de exprimir e perseguir valores econômicos, segundo o paradigma do direito de propriedade. São direitos subjetivos não patrimoniais, no sentido de estarem previstos e tutelados pelo direito objetivo. Assim, todos os direitos subjetivos que não tenham objeto econômico e sejam inerentes e essenciais à realização da pessoa, especialmente nas relações privadas, são direitos da personalidade" (LÔBO, Paulo. *Direito Civil. Parte Geral*. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 145-146).

73 PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*. T. I. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p. 158.

74 PERLINGIERI, Pietro. *Perfis de Direito Civil*. Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 120. Conferir, também, do mesmo autor: La personalità umana nel ordinamento giuridico. In: *La persona i suoi diritti*. Napoli: ESI, 2005.

estariam melhor resguardadas não com a tradicional categoria conceitual do direito subjetivo, mas sim com a categoria da situação jurídica. Seja como for, os direitos da personalidade lidam melhor com normas abertas, normas flexíveis que possuam maleabilidade bastante para possibilitar o exercício de todas as potencialidades existenciais.

Cabe outra observação: melhor e mais exato é afirmar que a ordem jurídica *reconhece* a personalidade humana. Não há, a rigor, criação, mas reconhecimento[75]. Quando falamos em reconhecimento, no entanto, não invocamos valores jusnaturalistas, mas dimensões e camadas históricas que não aceitam retrocesso. Construímos historicamente determinadas realidades e valores que a ordem jurídica não pode desconhecer ou apagar. O substrato, social e valorativo, antecede à formulação jurídica, embora a dimensão jurídica acrescente outros graus, mais sólidos, de proteção e resguardo, essenciais à integridade desses valores.

11.1. Direitos de personalidade e pessoas jurídicas: como compatibilizar?

A matéria, no Brasil, revestiu-se de certa polêmica no âmbito doutrinário. Há certo olhar doutrinário[76] que entende que a cláusula geral de tutela da pessoa humana, simbolizada na dignidade, não é aplicável à pessoa jurídica, despida dessas dimensões existenciais próprias. Admitia-se, no máximo, o chamado "dano institucional", que seria o dano sofrido pelas pessoas jurídicas sem fins lucrativos (fundações e associações, por exemplo). Essa posição, no entanto, não foi a que prevaleceu entre nós.

Lembremos que, historicamente, o próprio termo (e o próprio conceito) de pessoa era restrito, inicialmente, aos seres humanos (embora não a todos, lamentavelmente). Só depois, aos poucos, foi ampliado para abranger certas organizações humanas, as pessoas jurídicas. O mesmo acontece, de certo modo, com os direitos da personalidade em relação às pessoas jurídicas. Não há razão para não reconhecer essa aplicação como possível – não, é verdade, de modo integral, mas de modo restrito e atento às especificidades. Pontes de Miranda, nesse sentido, já percebia que as pessoas jurídicas podem sofrer dano à honra e ao nome[77]. Não há, pensamos, decréscimo na proteção das dimensões existenciais do ser humano ao reconhecer que a pessoa jurídica, sob certos aspectos, também pode receber a proteção relativa aos direitos da personalidade.

Portanto, não são apenas as pessoas físicas que são destinatárias dos direitos da personalidade. Alguns desses direitos – não todos – são atribuíveis, também, às pessoas jurídicas. Assim, o direito ao nome, por exemplo – embora cercado de especificidades no caso das pessoas jurídicas – pode ser lembrado, bem como o direito

[75] Em sentido semelhante: SZANIAWSKI, Elimar. *Direitos da personalidade e sua tutela*. São Paulo: RT, 2005, p. 241. Também: BITTAR, Carlos Alberto. *Os direitos da personalidade*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 7. Afirmar que a ordem jurídica não os cria, apenas os reconhece, não significa negar a construção histórica que perpassa tais direitos. O que defendemos é que a ordem jurídica não pode legitimamente desconhecer essa construção histórica, seria social e juridicamente impossível retroceder ou negar tais direitos.

[76] Cf. TEPEDINO, Gustavo. *Temas de Direito Civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. O Enunciado n. 286 das *Jornadas de Direito Civil* proclamaram: "Os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos".

[77] PONTES DE MIRANDA. *Tratado de Direito Privado*. T. VII. São Paulo: RT, 1983, p. 46. Lembrava Pontes que "as pessoas jurídica também podem ser ofendidas em sua honra, porque é comum às pessoas físicas e as jurídicas o bem da reputação, da boa fama".

ao sigilo de correspondência. Talvez o melhor exemplo, entretanto, seja o direito à honra. O Código Civil, a respeito, dispôs que aplica-se "às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade". Nossa jurisprudência pacificou-se no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula 227). Temos, portanto, na hipótese, induvidosamente direito da personalidade, embora a honra em questão seja a honra objetiva.

Aliás, em muitos setores não só dos direitos da personalidade, mas também – de modo mais amplo – relativo aos direitos humanos, as pessoas jurídicas têm sua legitimidade para atuar reconhecida. A Convenção Europeia de Direitos Humanos possibilita que tanto as pessoas físicas como jurídicas reclamem a proteção de direitos humanos (art. 25.1). O Tribunal Constitucional da Espanha, em linha semelhante, reconheceu a existência de direitos fundamentais relacionados à pessoa jurídica – observadas, por certo, suas especificidades[78]. Talvez seja interessante mencionar, também, o CPC/2015, cujo art. 98 previu: "A pessoa, natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Ou seja, o benefício da justiça gratuita é extensível às pessoas jurídicas.

11.2. Os animais podem ser considerados sujeitos de direito no século XXI?

Já tratamos do tema neste livro. Convém apenas, com extrema brevidade, retomar a questão neste capítulo. À luz dos conceitos desenvolvidos pela teoria geral do direito dos séculos passados, a pergunta acima – os animais podem ser sujeitos de direito? – poderia até soar absurda. Animais, tradicionalmente, são objeto de direito, objeto, portanto, de relações jurídicas. Jamais poderiam ser considerados sujeitos. Não podemos dizer, hoje, que a situação se inverteu, mas também não podemos dizer que ela é absolutamente tranquila, plácida, indiscutível, como era antes. As inovações que o direito experimentou, nas últimas décadas, trouxeram impactos relevantes não só nas *funções*, mas também na *estrutura* da teoria geral do direito (aliás, é cada vez mais difícil falar em teorias gerais, amplas, como fazíamos no século XIX).

Como reconhece Annelise Steigleder, "a atribuição de dignidade a seres não humanos ainda é um tema em construção, não plenamente assimilado no discurso jurídico"[79]. Seja como for, não se aceita, atualmente, que os animais sejam equiparados aos demais bens – como os minerais, por exemplo. Até mesmo uma postura antropocêntrica não radical reconhece que os animais devem ser tratados de modo não cruel e que devem receber cuidados diferenciados. O bem estar dos animais passa a ser item relevante da pauta. Seja como for, reconhecer que os seres da natureza ostentam um *status* próprio, peculiar e diferenciado, não significa reconhecer-lhes como sujeitos de direito, apenas que não podemos, indistintamente, *coisificar* a natureza, de modo insensível e desconforme com os avanços científicos mais recentes.

[78] Cf. EKMEKDJIAN, Miguel Ángel; PIZZOLO, Calogero. *Hábeas data:* el derecho a la intimidad frente a la revolución informática. Buenos Aires: Depalma, 1996, p. 93.

[79] STEIGLEDER, Annelise Monteiro. *Responsabilidade civil ambiental*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 154.

É inevitável constatar que a matéria persiste polêmica e não há unidade de vistas. Talvez ainda não estejamos prontos, à luz das estruturas e funções do nosso sistema jurídico, para reconhecer a posição de sujeito de direito para os animais. O que não significa que possamos instrumentalizá-los como coisas, sem consideração específica com seres que merecem consideração específica. Parece-nos fora de dúvida, atualmente, à luz dos postulados éticos de nosso sistema jurídico, que é dever do Estado e da sociedade tratar os animais sem crueldade. Não só isso: deve-se, por todos os modos e por todas as formas, com os instrumentos jurídicos disponíveis, reduzir o sofrimento de seres que sentem dor. Trata-se de questão ética relevante a que o direito do século XXI não pode permanecer indiferente, sob velhas escusas formais.

11.2.1. Estatuto Jurídico dos Animais: nova qualificação jurídica em Portugal (Lei n. 8/2017)

Embora seja importante mencionar a experiência portuguesa (por ser recente), ela não foi a primeira. Os países que largaram na frente em relação ao tema foram Alemanha, Suíça, Áustria e França. Os três primeiros (Alemanha, Suíça e Áustria) deixaram claro em seus códigos que os animais não são coisas ou objetos. A França, em 2015, deu um passo além: introduziu uma proteção afirmativa, ao afirmar que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade. O Código Civil português foi alterado, em 2017, a partir do chamado Estatuto Jurídico dos Animais. A norma prevê que "o direito de propriedade de um animal não abrange a possibilidade de, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus tratos que resultem em sofrimento injustificado, abandono ou morte" (Código Civil português, art. 1.305-A, 3). O Estatuto começou a vigorar em 01 de maio de 2017. Nesse contexto, o direito português caminha no sentido de reconhecer aos animais uma nova qualificação jurídica. Não seriam mais coisas – neutras e disponíveis – no sentido jurídico, como sempre foram enxergados. Teriam uma qualificação intermédia entre a coisa e o ser humano. O Estatuto português reconhece os animais como "seres dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica". Prevê ainda que em caso de separação entre casais, "os animais de companhia são confiados a um ou ambos os cônjuges, considerando, nomeadamente, os interesses de cada um dos cônjuges e dos filhos do casal e também o bem-estar do animal" (Código Civil português, art. 1.793-A).

No Brasil, o STJ, em 2018, através de sua quarta turma, garantiu a ex-companheiro o direito de visitar animal de estimação após dissolução de união estável. Com a decisão, o ex-companheiro teve garantida a possibilidade de visitar uma cadela *yorkshire* que ficou com a mulher depois da separação (o processo tramitou em segredo de justiça por isso não temos o número do julgado). O relator destacou: "Penso que a solução deve, realmente, depender do caso concreto, mas será resguardada a ideia de que não se está frente a uma 'coisa inanimada', mas sem lhe estender a condição de sujeito de direito. Reconhece-se, assim, um terceiro gênero, em que sempre deverá ser analisada a situação concreta, voltado para a proteção do ser humano e seu vínculo afetivo com o animal".

12. A LIBERDADE DE INFORMAR E DE SER INFORMADO COMO DIREITO FUNDAMENTAL

A liberdade de informar e de ser informado caracteriza-se, nas democracias constitucionais contemporâneas, como direito fundamental. Sem isso boa parte dos outros direitos estaria esvaziada, sobretudo as chamadas liberdades públicas. Não é possível votar, exercer o direito (fundamental) à fiscalização dos atos de governo, fazer um juízo sobre os melhores caminhos para o país sem acesso livre à informação. Atualmente, aliás, o cidadão não é mais – ou não deveria ser – aquela figura que recebe passivamente informações produzidas por outrem. Hoje todos influenciam e são influenciados. Há interações em rede, velozes e simultâneas. Essas interações redefinem, de modo dinâmico, as escolhas sociais e influenciam nas ações dos governos e nas decisões coletivas.

Já mencionamos antes que o Estado Constitucional de Direito pode ser considerado um Estado de ponderação (*Abwägungsstaat*). Todo conflito entre liberdade de informação e privacidade é fundamentalmente uma questão constitucional. Já frisamos que o Código Civil não foi nada feliz ao tratar dos direitos da personalidade. O art. 20, por exemplo, dispõe: "Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais". O Código Civil, nascido já no século XXI, não menciona a liberdade de expressão! A norma hierarquiza, de modo estático, bens jurídicos de um modo que se distancia das opções valorativas básicas da Constituição. Nota-se que o "art. 20 do Código Civil, que representa uma ponderação de interesses por parte do legislador, é desarrazoado, porque valora bens constitucionais de modo contrário aos valores subjacentes na Constituição. A opção do legislador, tomada de modo apriorístico e desconsiderando o bem constitucional da liberdade de informação, pode e deve ser afastada pela interpretação constitucional"[80]. Lembremos que há interesse público na própria liberdade de informação. Podemos falar, no contexto descrito, na *função social da livre circulação das informações*.

12.1. As múltiplas fontes de informação: interações em rede

Convém destacar, com clareza, algo que já falamos (cremos que a separação da matéria em itens breves facilita a compreensão). A liberdade de informar não é privativa dos veículos de imprensa. Hoje todos – de certo modo – a tem. Com a internet e as redes sociais, as notícias perderam o foco de emissão único, fechado, que tinham no passado. O fenômeno tem aspectos positivos e negativos (mais positivos que negativos, em nossa opinião), mas, gostemos ou não, é um fato. Já dissemos também que observa-se uma passagem, em nossos dias, do sujeito isolado para o

[80] CASTANHO DE CARVALHO, Luís Gustavo Grandinetti. Direito à informação x direito à privacidade. O conflito de direitos fundamentais. *Revista da AMAERJ*, n. 5, 2002, p. 15.

sujeito conectado. Na esfera jurídica, os o direito não opera mais – pelo menos não exclusivamente – na lógica do *um-contra-um*. Há uma relevante dimensão coletiva e difusa que se fortalece. Nascem novos sujeitos de direito, nascem novos interesses que os séculos anteriores mal poderiam adivinhar. Os bens jurídicos redefinem-se de modo intenso. O direito de informar e ser informado – com liberdade e sem obstáculos – apresenta-se como bem jurídico de singular relevância constitucional. Lembrando que devemos encarar esse direito de modo dinâmico, como algo que potencialmente pode ser exercido por todos, e à luz da *função social da livre circulação das informações*.

12.2. Critérios hermenêuticos: definindo alguns passos

"Ser natural é a mais difícil das poses".

Oscar Wilde

Cabe sintetizar alguns critérios hermenêuticos que nos parecem relevantes para auxiliar o intérprete em tema tão delicado: a) Em linha de tendência, a liberdade de expressão e comunicação não deve encontrar obstáculos jurídicos, sobretudo se prévios ao seu exercício; b) os abusos, quando configurados, são atos ilícitos (Código Civil, art. 187), e perfazem danos indenizáveis, possibilitando a imposição de sanção exemplar, punitiva e pedagógica; c) a sátira e o humor, mesmo quando incisivos, devem ser admitidos, salvo quando instrumentalizem o ser humano, tornando-o, digamos assim, menos humano; d) o direito de resposta é uma forma de tutela específica que pode ser concedida pelo magistrado, de modo exclusivo ou cumulado com a indenização, mesmo após o STF ter decidido pela não recepção da Lei de Imprensa pela Constituição de 1988 (convém lembrar que desde 2015 temos a Lei n. 13.188, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada por veículo de comunicação social); e) embora não se admitam posturas levianas, não são exigíveis da imprensa o mesmo grau de certeza da prova produzida em juízo, por exemplo; f) recomenda-se ao intérprete, na matéria, especial cuidado para não escalonar o direito à imagem à luz da condição social ou econômica do ofendido.

O nosso foco, nas próximas páginas, será sobretudo a objetividade, diante do limite de espaço que define esta obra. A ideia não é esgotar o assunto, mas oferecer um norte seguro. Até pensamos se manteríamos ou não os próximos tópicos (mais adequados em tratados ou livros específicos. Mas, por acreditar que podem ser úteis ao leitor, resolvemos manter, embora de forma concisa).

12.2.1. As liberdades comunicativas devem encontrar limites prévios ao seu exercício?

Apenas de modo absolutamente excepcional, e com imenso ônus argumentativo, o julgador deve determinar a proibição da veiculação da notícia. Mesmo porque, dada a incrivelmente veloz partilha de informações que ocorre em nossos dias, o efeito

quase sempre é contrário ao pretendido. O STF já decidiu que "a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação de ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas" (STF, Pleno, ADPF 130, 06/11/2009). Devem ser evitadas quaisquer medidas, judiciais ou administrativas, que turbem o direito à livre circulação de notícias e opiniões. Lembremos que a Constituição Federal, art. 5º, IX, assegura ser "livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença". Mais adiante, no inciso XIV, garante "a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional". O STF já teve oportunidade de destacara "primazia prima facie da liberdade de expressão no processo de ponderação. Seu afastamento há de ser a exceção e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto" (STF, ADI 4815, voto do Min. Barroso). Deverá haver, nesse contexto, a preferência por medidas que não envolvam a proibição prévia da divulgação (proibição prévia de livros, jornais, revistas, reportagens etc.)[81]. Defende-se por exemplo, que "qualquer ação para inibir as chamadas *fake news* deve passar por mais informação e não menos. Assim, propostas que permitam a remoção sem ordem judicial de conteúdos, bem como que prejudiquem a mídia alternativa e criminalizem todo aquele que publicar conteúdo falso, deverão ser evitadas por não se alinharem com a Constituição e a proteção das liberdades fundamentais"[82].

12.2.2. Os abusos, quando configurados, são atos ilícitos

O abuso de direito é ato ilícito (Código Civil, art. 187). Seus efeitos são variados, não apenas indenizantes. Não basta, na sociedade contemporânea, ter direito, é fundamental que seu exercício não se dê de modo agressivo ou ilimitado, rompendo a harmonia social. Há deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade (STJ, REsp 1.382.680, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T, DJ 22/11/2013). O dever geral de cuidado diz respeito à projeção, por parte de quem publica, das consequências oriundas da divulgação; o dever de veracidade tem relação com o não falsear o que se publica, nem fazer conjecturas pejorativas; o dever de pertinência

[81] RODRIGUES JR, Edson Beas. Solucionando o conflito entre o direito à imagem e à liberdade de expressão: a contribuição da Corte Interamericana de Direito Humanos. *Revista dos Tribunais*, v. 905. São Paulo, 2011, p. 92. Seja como for, não são admissíveis alegações de direito à intimidade quando estão em jogo recursos públicos. O gestor de dinheiro público deve, obviamente, agir com total transparência (e estar pronto para aceitar cobranças nesse sentido), sendo contrária à Constituição qualquer interpretação que crie sofismas nesse campo. O dever de transparência pode eventualmente atingir os negócios particulares, uma vez que quem deseja se apropriar de recursos públicos – ou de valores privados, como pagamento de "favores" prestados na função pública – usa caminhos tortuosos e obscuros, para esconder a origem ilícita dos valores. O dever de transparência, no caso, se impõe de modo particularmente forte, prestigia e exalta os valores constitucionais. É preciso, também, que seja oferecido ao envolvido o direito de apresentar sua versão sobre a denúncia.

[82] TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Fake news: como garantir liberdades e conter notícias falsas na internet? In: MENEZES, Joyceane Bezerra de; TEPEDINO, Gustavo (Coord.). *Autonomia privada, liberdade existencial e direitos fundamentais*. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 525-543, p. 538). *As Jornadas de Direito Civil*, em 2018, com visão distinta, entenderam que "a liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro" (Enunciado 613).

autoriza indagarmos em que medida o conteúdo supostamente ofensivo guarda relação com o dever de informar (não há pertinência, por exemplo, numa matéria sobre compras de Natal, um comentário ofensivo acerca da conduta de alguém). As peculiaridades do caso concreto são sempre relevantes.

12.2.3. A sátira e o humor, mesmo quando incisivos, devem ser admitidos

> *"Sabemos que o brasileiro é o único povo que faz piada. Se não temos um vampiro, estejam certos: é a piada que torna inviável qualquer Drácula brasileiro".*
>
> Nelson Rodrigues

Não é simples nem fácil delimitar as fronteiras entre o humor e o dano indenizável (costumamos nos esquecer ou nos fingir de distraídos, mas a verdade é esta: boa parte das piadas que rimos, às vezes as mais engraçadas, são de certo modo ofensivas a alguém, reforçam algum esteriótipo negativo, diminuem determinado gênero, raça, origem etc). Por outro lado, o humor tem imensos aspectos positivos e necessários, exerce, além disso, função de relevância coletiva na crítica política e de costumes. São dimensões culturais que precisam ser lembradas. A sátira, em si, não é depreciativa. O mesmo se diga da paródia. Em determinado caso concreto, uma empresa de hortifrutigranjeiros alterou, na publicidade, um verso da canção *Garota de Ipanema*, transformando: "Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça" em "Olha que *couve* mais linda, mais cheia de graça". Diante disso, a empresa detentora dos direitos autorais da canção (*Garota de Ipanema*) pediu a proibição da veiculação da referida publicidade, o que não foi aceito. O STJ decidiu em 2018 que a paródia é possível e traduz livre manifestação do pensamento, desde que haja efetiva atividade criativa por parte do parodiador e que não haja tom depreciativo ou ofensivo, que enseje descrédito em relação à obra parodiada (STJ, REsp 1.597.678).

É preciso sempre contextualizar a discussão. A piada, a sátira, a ironia são admissíveis, mesmo quando corrosivas e fortes. A situação pode assumir outros contornos quando atinge a integridade física de alguém, como nas chamadas "pegadinhas". Por exemplo, mulher que, enquanto caminha na rua, tem baratas vivas arremessadas contra o seu corpo, sobretudo quando a vítima tem verdadeiro pânico – o que ocorre com muitas mulheres – desse inseto (STJ, REsp 1.095.385). Ou alguém que é atingido por baldes de terra enquanto desempenha seu trabalho (STJ, AgRg no Ag 1.348.247). O dano se faz indenizável sobretudo se as imagens são veiculadas sem autorização (a autorização para veiculação, nesses casos, é imprescindível). Se podemos, muitas vezes, encarar a situação com bom humor e relevar esse ou aquele aborrecimento, em outras vezes há, de fato, linhas de razoabilidade que são ultrapassadas. De todo modo, ninguém está obrigado a aceitar essa veiculação, caso não queira.

O STF, em 2018, por unanimidade, declarou inconstitucionais os dispositivos da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) que impediam emissoras de rádio e televisão de veicular programas de humor envolvendo candidatos e partidos nos três meses anteriores ao pleito, como forma de evitar que sejam ridicularizados ou satirizados

(STF, ADI 4451). Entendeu-se corretamente que os artigos violam as liberdades de expressão e de imprensa e o direito à informação.

12.2.4. O direito de resposta como tutela específica

O direito de resposta representa uma tendência dos nossos dias: *despatrimonializar* os meios e modos da reparação do dano. O direito de resposta é uma forma de tutela específica que pode ser concedida pelo magistrado, mesmo após o STF ter decidido pela não recepção da Lei de Imprensa pela Constituição de 1988. O STF, ao julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) nº 130, entendeu que a Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) não foi recepcionada, em sua integralidade, pela Constituição Federal de 1988. A resposta veiculada deve ser concisa, clara, objetiva, e não ostentar tintas ofensivas. O STJ, aliás, já se posicionou em sentido semelhante ao afirmar que "não há de se confundir direito de resposta com direito de vingança, porquanto aquele não constitui crédito ao ofendido para que possa injuriar ou difamar o seu ofensor" (STJ, REsp 296.391). O direito de resposta pode se apresentar como tutela específica autônoma, exclusiva. Ou pode se apresentar acompanhado da tutela ressarcitória, da indenização.

12.2.4.1. A lei do direito de resposta (Lei n. 13.188/2015)

Em novembro de 2015 foi sancionada a Lei n. 13.188, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada ou transmitida por veículo de comunicação social. Convém frisar, em linha de princípio, que a referida lei nasceu enfrentando forte polêmica quanto à sua conveniência, quanto ao acerto das escolhas por ela feitas e, até, quanto à sua constitucionalidade. A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) insurgiu-se, perante o STF, contra a nova lei, pedindo que todo o texto da nova lei seja declarado inconstitucional. A OAB, anteriormente, já havia atacado, perante o STF, certos trechos da lei[83]. O Ministro Carlos Ayres Brito, que relatou, no STF, a ADPF 130 – que considerou integralmente não recepcionada, pela Constituição Federal de 1988, a Lei de Imprensa – declarou, a propósito da

[83] A Lei n. 13.188/2015 faz explícita ressalva no sentido de que ela não se aplica aos comentários realizados por usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social (art. 2º, § 2º). A lei dispõe que a retratação ou retificação espontânea, ainda que a elas sejam conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, não impedem o exercício do direito de resposta pelo ofendido nem prejudicam a ação de reparação por dano moral (art. 2º, § 3º). Define que o direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo decadencial de 60 dias, contado da data de cada divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva, mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social ou, inexistindo pessoa jurídica constituída, a quem por ele responda, independentemente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo (art. 3º). Estatui que a resposta ou retificação – seja na "mídia escrita", na internet, na "mídia televisiva", ou na "mídia radiofônica" – terá o destaque, a publicidade, a periodicidade e a dimensão da matéria que a ensejou. Prevê ainda que a resposta ou retificação cuja divulgação, publicação ou transmissão não obedeça ao disposto nesta Lei é considerada inexistente. Os demais artigos da lei (fundamentalmente, do 5º ao 12º) estabelecem ritos procedimentais, e determinados requisitos, para a propositura e processamento da respectiva ação judicial. Requisitos, em geral, bastante severos em relação aos veículos de comunicação em geral (estabelece, em geral, prazos bastante exíguos e elimina, por exemplo, no art. 10, a possibilidade de um juízo monocrático no âmbito dos tribunais, entre outras medidas que destoam dos padrões normativos brasileiros). A lei, de fato, parece fugir à proporcionalidade, e pode-se cogitar que ela pretenda dificultar a livre circulação das ideias e informações tão própria de um regime democrático.

nova lei do direito de resposta: "A lei trabalha mal com as categorias constitucionais sobre liberdade de imprensa e direito de resposta. Também não compreendeu bem as decisões do Supremo, como o fim da Lei de Imprensa. Ela foi hostil à liberdade de imprensa e pensamento". O texto legal, de fato, parece presumir o abuso, e não o valor constitucional da liberdade de imprensa.

12.2.5. Quem responde por danos causados através da imprensa?

Artigos e matérias publicados em jornais ou revistas – assinados ou não, físicos ou digitais – frequentemente são objeto de demandas judiciais. Uma pergunta prévia é esta: contra quem deve ser dirigida a ação? Quem figurará no polo passivo da demanda? O STJ já teve oportunidade de analisar a questão, decidindo que os jornalistas são civilmente responsáveis, ao lado do dono do veículo de comunicação, por aquilo que publicam (STJ, Súmula 221: "São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escritor quanto o proprietário do veículo de divulgação"). Esse entendimento se aplica a todas as formas de imprensa, alcançado, assim, também os serviços de provedoria de informação, cabendo àquele que mantém blog exercer o seu controle editorial, de modo a evitar a inserção no site de matérias ou artigos potencialmente danosos (STJ, REsp 1.381.610).

O jornalista que calunia ou difama comete ato ilícito, respondendo civilmente pelos danos materiais e morais causados (Código Civil, art. 186 ou 187 c/c art. 927). Assim, o "profissional que assina a reportagem classificada de agressiva ou injuriosa tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação compensatória ajuizada pelo ofendido. Precedentes" (STJ, AgRg no REsp 1.041.191). A jurisprudência anota que "todos aqueles que concorrem para o ato lesivo decorrente da veiculação de notícia na imprensa podem integrar o polo passivo da ação de responsabilidade civil" (STJ, AgRg no Ag. 702.321). Já se ressaltou, contudo, que o "sócio da pessoa jurídica proprietária da revista em que publicada a matéria ofensiva, em princípio, não responde solidariamente com a empresa pela indenização do dano" (STJ, REsp. 336.783).

12.2.5.1. Exige-se da imprensa o grau de certeza da prova judicial?

> *"Para evitar processos, jornalistas aprendem a chamar um assassino de suposto assassino".*
>
> Stephen Leacock

Os veículos de comunicação não operam – nem poderiam –, na apuração e divulgação de notícias, com os mesmos graus de solidez e certeza exigíveis num processo judicial (sobretudo se penal). Há interesse público, ademais, na divulgação célere e transparente das notícias, é algo que conquistamos e não saberíamos – socialmente falando – ficar sem isso, é um passo democraticamente irreversível. Outro ponto relevante é assentar que o dever de indenizar por parte do veículo de imprensa não surge, de modo automático, com a absolvição daquele a cujo respeito foi publicada notícia relativa à acusação ou suspeita.

Exige-se, isso sim, da imprensa, que atue de modo diligente, que busque a verdade, que sempre ouça (e publique) a versão da outra parte. Aliás, como costuma ocorrer em muitas áreas, com o tempo o público aprende a distinguir a publicação séria daquelas outras menos comprometidas com a busca da isenção e da verdade. Os leitores aprendem a dar pesos diferentes a notícias não só pelo conteúdo que eventualmente tragam, mas também pelos mensageiros que as trouxeram – isto é, julgam o veículo em si. Não deixa de ser democraticamente saudável esse aprendizado. Essa constatação, no entanto, não autoriza a imprensa a publicar notícias sem a mínima base factual, sobretudo se ofensivos à honra de alguém. Quer dizer, até poderá publicar, mas deverá responder civilmente por isso.

12.2.5.2. Lei de imprensa: não recepção pela Constituição de 1988

Mencionamos que os dilemas que envolvem a imagem hoje costumam envolver questões constitucionais. Isso é ainda mais forte nos conflitos entre liberdade de imprensa e informação, de um lado, e honra e privacidade de outro, porque não temos legislação infraconstitucional específica (em vigor) sobre a matéria. Em relação à Lei de Imprensa – Lei n. 5.250/67 – vale lembrar que o STF, julgando a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, declarou a não recepção da lei pela Constituição de 1988, em sua integralidade. O STF assentou que se aplicam à matéria as normas da legislação comum.

13. CONTEXTUALIZANDO O USO DA IMAGEM ALHEIA

Além dos tópicos que destacamos nos itens anteriores, poderíamos continuar elencando algumas particularidades que nos parecem relevantes na matéria. Os pontos são os seguintes: a) pode haver lesão à imagem com ou sem simultânea lesão à honra; b) a autorização que alguém eventualmente dê para o uso de sua imagem deve ser interpretada de modo restrito, não cabendo hermenêutica ampla; c) fotos de multidões ou em lugares públicos (praias, por exemplo), se não destacam alguém em especial, não lesam o direito à imagem; d) o uso de imagem de crianças e adolescentes deve ser excepcional e contextualizado, cabendo, em linha de princípio, optar pelo resguardo da imagem e não exibição; e) a indenização por lesão à imagem não se condiciona a prova de prejuízo pelo ofendido nem tem como teto o lucro do agressor (quando houver).

13.1. Violação à imagem com ou sem violação à honra: diferenciações

Pode-se violar o direito à imagem de duas formas: a) violação da imagem com violação à honra; ou b) violação da imagem sem violação à honra. As hipóteses, embora conexas, não se confundem. Se, digamos, um jornal faz uma reportagem investigativa sobre corrupção e insere, por engano, a foto de um inocente na reportagem (haverá violação à imagem e à honra). Ou, de modo muito mais dramático, como aconteceu no tristemente célebre caso da Escola Base, ocasião em que falsas